UNIVERSIDADE LaSalle
Viver é evoluir.

NOVA GRADUAÇÃO UNIVERSIDADE LA SALLE

UNIDADE 2

Direito DIGITAL

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

unidade
2
V.1 | 2023

Propriedade Intelectual

Prezado estudante,

Estamos começando uma unidade desta disciplina. Os textos que a compõem foram organizados com cuidado e atenção, para que você tenha contato com um conteúdo completo e atualizado tanto quanto possível. Leia com dedicação, realize as atividades e tire suas dúvidas com os tutores. Dessa forma, você, com certeza, alcançará os objetivos propostos para essa disciplina.

Objetivo Geral

Abordar o direito digital face ao contexto das novas tecnologias, e as relações de proteção patrimonial referente à exploração econômica da obra.

Editora
LaSalle

unidade
2
V.1 | 2023

Parte 1

Direitos Autorais

O conteúdo deste livro
é disponibilizado
por SAGAH.

SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Direitos autorais

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir direito autoral.
- Classificar os direitos autorais.
- Identificar quem pode ser titular dos direitos autorais.

Introdução

Neste capítulo, você vai ler sobre os direitos autorais, uma das espécies do instituto da propriedade intelectual. Concentraremos nossos estudos em conhecer a história e o conceito dos direitos autorais, bem como o que pode e o que não pode ser protegido. Após, veremos que os direitos autorais são classificados em direito moral e direito patrimonial, divisão importante para finalizarmos o estudo com a identificação de quem pode ser titular de direitos autorais e de que forma esses direitos podem ser transferidos para terceiros.

Direito autoral

O direito autoral é, ao lado da propriedade industrial, uma das espécies dos chamados direitos intelectuais que compõem o gênero **propriedade intelectual**. Se considerarmos uma classificação básica excluindo os direitos *sui generis*, temos, de um lado, a legislação que protege as criações voltadas para a exploração econômica (Lei da Propriedade Industrial) e, do outro, a legislação que visa salvaguardar a vontade do criador (Lei de Direitos Autorais), embora ela também regule o caráter patrimonial, conforme veremos adiante.

Os termos direito autoral e direitos autorais são sinônimos, pois se subentende que eles são gênero da subclassificação descrita na própria Lei de Direitos Autorais, cujo art. 1º destaca que ela visa regular os direitos autorais, entendendo-se, sob essa denominação, os direitos de autor e os que lhe são conexos. A lei inclui os direitos conexos aos direitos de autor como espécie

do direito autoral (ou direitos autorais), estabelecendo uma clara diferença entre as terminologias, muitas vezes utilizadas, na prática, como sinônimas.

Paralelamente, ainda há uma terceira espécie de direitos autorais, regulada por outra legislação, que é a Lei do Programa de Computador (Lei nº. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998), também conhecida como a Lei do *Software*.

Por não ser objeto de estudo aqui, não trataremos das espécies de direitos conexos e programa de computador para que consigamos reconhecer o direito autoral por meio das premissas básicas do direito de autor.

Breve histórico

Sem a pretensão de esgotar o tema, vamos analisar alguns detalhes históricos que envolveram a criação da Lei de Direitos Autorais no Brasil, objetivando compreender a natureza jurídica desse fenômeno para situá-lo corretamente no nosso sistema jurídico.

A doutrina especializada costuma fazer um apanhado das primeiras ações que indicavam o surgimento do que hoje seria o direito autor, mas interessa referir que foi no século XV que os direitos autorais passaram a tomar certa relevância com a **criação da tipologia e da imprensa**, quando foi possível reproduzir, mediante impressão, as obras, especialmente literárias, de maneira mais rápida e sem a intervenção do autor, alcançando, assim, um maior número de pessoas e lugares.

Com essa facilidade de reprodução das obras literárias, surgiu o interesse dos livreiros e dos editores da época em criar os primeiros privilégios de exploração econômica das obras. Sem qualquer tipo de garantia ou direito, os autores só conseguiram quebrar o monopólio dos livreiros e dos editores quando a rainha Ana, da Grã-Bretanha, assinou o ***Copyright Act***, em 1710, o qual estimulava a criação de obras com a contrapartida da garantia de um direito exclusivo de reprodução, embora tratasse o direito autoral de forma muito genérica.

Foi apenas na **Convenção de Berna** para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas, assinada em 1886, que os direitos autorais, como são hoje conhecidos, foram regulados e ampliados para o campo artístico e científico, além da já conhecida área literária. Pouco tempo após a revisão da Convenção de Berna, em 1971, ela foi promulgada no Brasil por meio do Decreto nº. 75.699, de 6 de maio de 1975, no qual vinha expressamente prevista a proteção da obra intelectual.

Na década seguinte, a Constituição Federal do Brasil de 1988 trouxe o reconhecimento do direito do autor da obra intelectual como um direito fundamental,

consignando que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

Atualmente, os direitos autorais são regulados pela Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, a qual revogou a maior parte dos dispositivos da Lei de Direitos Autorais anterior: Lei nº. 5.988, de 14 de dezembro de 1973.



Fique atento

Os direitos autorais são regidos por lei específica no Brasil, ancorados pela Convenção de Berna, que, passados todos esses anos, pouco foi alterada em relação à sua redação original e ainda é muito recorrida em casos de dificuldade na interpretação dos dispositivos legais da lei brasileira ou em caso de conflito de direitos entre dois ou mais países.

Conceito de direito autoral

Um destaque que precisamos fazer é que existem dois sistemas que estruturam os direitos de autor. Um deles é o **sistema anglo-americano**, também conhecido como *copyright*, que visa proteger a obra e a sua possibilidade de reprodução, e o outro é o **sistema francês**, também chamado de *droit d'auteur*, que se preocupa mais em proteger os direitos do criador da obra. O Brasil se filiou ao sistema francês, privilegiando, portanto, o direito do autor das obras intelectuais.

A doutrina nacional utiliza diversas maneiras para conceituar o direito autoral, mas o consenso entre elas é de que o direito autoral representa o conjunto de direitos destinados a regular as relações jurídicas decorrentes da criação de obras intelectuais protegidas, sejam elas de ordem moral ou patrimonial.

Na medida em que o direito autoral se destina a proteger as criações intelectuais, verificamos que a Lei de Direitos Autorais se preocupou em definir-las como as criações de espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro.

Na doutrina, encontramos que as criações de espírito exteriorizadas são as criações intelectuais caracterizadas pela originalidade e forma de expressão, que consiste na obra intelectual. A obra intelectual é a expressão de uma evolução característica do pensamento, uma criação de espírito, e a sua originalidade se caracteriza por ela não ser cópia de uma obra já protegida, independentemente de ter novidade ou mérito artístico (PIMENTA, 1998).

De acordo com a lei e a doutrina, para que as obras intelectuais sejam protegidas pela legislação, elas precisam decorrer da atividade de criação intelectual humana, ser exteriorizada sob qualquer forma e ser original. Basicamente, demonstrado o preenchimento desses três requisitos, podemos dizer que estamos diante de uma obra intelectual protegida pela Lei de Direitos Autorais, a qual exemplifica, mas não esgota, as **obras protegidas**, sendo as mais conhecidas identificadas como (BRASIL, 1998):

- textos de obras literárias, artísticas, científicas ou dramáticas;
- composições musicais;
- obras fotográficas;
- obras de desenho, pintura, gravura e escultura;
- projetos;
- esboços de obras plásticas concernentes à engenharia e à arquitetura;
- dicionário;
- programa de computador.



Fique atento

Sobrevém dessa análise que a proteção legal não demanda maiores dificuldades tais quais se verifica na propriedade industrial, pois basta que a criação intelectual humana seja, de alguma forma, materializada e não configure uma cópia ou reprodução de outra obra anterior para obter as benesses e exercer a gama de direitos colocados à disposição do autor.

O que não é protegido pelo direito autoral

Embora a legislação autoral seja bastante abrangente naquilo que concerne a uma obra intelectual protegível, ela se preocupou, também, em declarar expressamente, no seu art. 8º, tudo aquilo que não pode ser considerado passível de proteção.

Nesse sentido, são corriqueiros os questionamentos relacionados aos motivos pelos quais algumas criações não podem desfrutar da proteção da Lei de Direitos Autorais, e o motivo é que muitos se esquecem de verificar o rol de situações literalmente afastadas pelo legislador.

Saiba mais

O rol completo de situações não consideradas como obra intelectual consta no art. 8º da Lei de Direitos Autorais:

https://goo.gl/ktJ6gr

Poderíamos, aqui, tecer longos argumentos para justificar a não proteção dessas situações referidas, mas o importante é não esquecermos que a Lei de Direitos Autorais surgiu como uma forma de estimular a criação de obras intelectuais de impacto para a sociedade, como forma de facilitar o acesso à informação e ao conhecimento. Por esse motivo, entre outros tantos, não podemos reconhecer o direito de um juiz, por exemplo, de retirar as suas sentenças de circulação, como é permitido ao autor de uma obra intelectual protegida, sob pena de conflitar com o direito de publicidade dos atos processuais.

Além das decisões judiciais, a lei afasta a proteção das ideias. Nesse ponto, residem os maiores problemas quando não se tem firme os conceitos legais pertinentes. Nós, seres humanos, estamos constantemente criando por meio dos nossos pensamentos. A partir do momento em que essas criações passam a ser exploradas economicamente, percebemos o seu real valor. No ambiente empresarial, por exemplo, as pessoas são constantemente estimuladas a apresentar novas ideias para conquistar os consumidores e superar a concorrência. Entretanto, para que essas ideias sejam protegidas como obra intelectual, elas precisam ser materializadas de alguma forma, não ser cópia ou reprodução de outras obras anteriores e não podem estar no rol de objetos não protegidos como direito autoral.

Esses são apenas exemplos de situações comuns que até poderiam, se considerarmos os requisitos básicos analisados, estar resguardadas pela Lei de Direitos Autorais, mas a mesma lei se preocupou em listá-los como não protegidos para preservar o acesso à informação e conter eventuais abusos decorrentes do mau uso dos direitos de autor.

Dessa maneira, o correto enquadramento de uma obra intelectual sob o pálio da proteção da Lei de Direitos Autorais passa pelo preenchimento dos requisitos e, logo após, pela verificação de se a obra não está relacionada nas situações enumeradas como não sujeitas ao amparo legal.

Forma de registro e prazo de duração

Feitas as verificações sobre a possibilidade de proteção de uma obra intelectual pelo direito autoral, emerge a dúvida de como registrá-la e como fazer o cálculo do prazo em que fica albergado pela legislação.

A lei autoral, é bem verdade, preocupou-se apenas em estabelecer os critérios necessários para proteger uma obra intelectual, não estabelecendo qualquer formalidade para o seu registro. Isso nos faz entender que a simples materialização da criação intelectual faz incidir, em favor do autor criador, os direitos e as garantias estabelecidas em lei. Podemos dizer, então, que a obra intelectual não precisa ser registrada para estar protegida (art. 18) (BRASIL, 1998). É prudente, e recomendável, que se faça a prova, sob qualquer modo válido, da data da criação da obra para fins de defesa em eventual contestação futura. Assim, não é necessário registrar uma música na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro ou um livro na Biblioteca Nacional, pois, mesmo sendo instituições já estruturadas para tais registros, a prova da autoria não possui forma ou procedimento definido em lei. Basta que seja possível prová-la.

Em sintonia com a ausência de forma para registro de uma obra intelectual, o autor também não precisa se preocupar com o prazo de duração do seu direito de autor, pois a lei o garante durante todo o tempo de vida do criador da obra. O caráter temporal do direito autoral inicia apenas no ano seguinte ao do falecimento do autor e se restringe ao direito patrimonial, o qual perdurará, como regra, pelo prazo de 70 anos contados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor (art. 41) (BRASIL, 1998).

Existem exceções à regra do prazo de duração do direito patrimonial de autor, as quais ainda serão objeto de análise neste capítulo.

Limitações do direito autoral

Superadas as condições iniciais e estando garantida a proteção da criação intelectual, vale ressaltar que os direitos sobre a obra suportam limitações em seu uso, cujas situações estão elencadas textualmente na lei para estabelecer que não constituem ofensa aos direitos autorais (arts. 46) (BRASIL, 1998). Algumas delas valem a referência por estarem presentes no dia a dia de muitas pessoas.

A Lei de Direitos Autorais estipula que cabe ao autor da obra intelectual protegida fazer o uso da forma que melhor lhe provier e que o uso, por terceiros, depende de autorização prévia e expressa do autor. Mas como ficam, por exemplo, as citações de obras em trabalhos acadêmicos e científicos?

Seguindo na linha do livre acesso ao conhecimento, a Lei de Direitos Autorais limitou o uso dos direitos autorais no caso de reprodução de pequenos trechos, desde que seja indicado o nome do autor e a origem da obra, permitindo que se possa averiguar o correto uso da informação refletida pelo autor em determinada obra literária.

Outra limitação importante diz respeito ao uso da obra intelectual como prova em processos judiciais ou administrativos. Não é possível ao autor reivindicar qualquer direito quando sua obra for utilizada para fins do descobrimento da verdade em um litígio, pois ela, nesse caso, está servindo para resolver um problema coletivo, exercendo, ainda que fora do contexto, a sua função social.

A paródia, tão comum em programas de rádio, televisão e internet, também exerce um papel limitador dos direitos autorais. O cuidado que precisa ser tomado, nessa situação, é com a reprodução da obra original, que deverá ser completamente distinta e não poderá implicar em descrédito à obra e ao autor. Essa subjetividade acaba sendo objeto de inúmeros processos judiciais, cabendo ao juiz decidir se eventual descrédito alegado pelo autor de fato se configura.



Exemplo

Um caso interessante que parou no Poder Judiciário foi o pedido de indenização da editora do cantor Roberto Carlos contra o comediante Tiririca em virtude do uso não autorizado de uma das suas músicas na campanha política de 2014, quando Tiririca concorreu para uma vaga de deputado federal. A alegação da defesa foi de que se tratava de uma paródia, mas o Poder Judiciário entendeu que o uso se dava exclusivamente para satisfação de interesses eleitoreiros, não para o humor e o entretenimento, descaracterizando a essência da paródia.

Não obstante as demais limitações expressamente previstas na lei, os exemplos destacados dão uma ideia da cautela que precisamos ter ao utilizar uma obra intelectual, sob pena de estarmos infringindo direitos protegidos e que sujeitam o ofensor às penalidades cíveis e criminais normatizadas para esses casos.

Classificação dos direitos autorais

A Lei Autoral afirma que pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Essa divisão é uma herança do sistema autoral

francês adotado pelo Brasil, que classificava os atributos do direito de autor em **moral** e em **patrimonial**.

A existência da divisão do direito de autor não retira a característica primordial da legislação em proteger o criador acima de tudo. Por mais que uma divisão possa sugerir diferenças marcantes, não é o caso quando se fala em direito moral e patrimonial do autor, pois este é consequência natural daquele, bastando analisarmos as etapas listadas na legislação.

Mesmo quando há a transferência do direito patrimonial de autor de uma obra, não é possível dizer que ele estará destacado do direito moral, o qual, como observaremos, conserva o seu vínculo perpétuo com o criador originário.

Direito moral de autor

Por se tratar de uma criação de espírito, do intelecto humano, a obra intelectual está umbilicalmente ligada ao seu criador, foco central da proteção da legislação autoral. O direito moral de autor é entendido como um direito da personalidade do autor e, por esse motivo, é inalienável e irrenunciável, conforme previsão expressa da lei. Embora não esteja normatizado, o direito moral de autor também é considerado perpétuo, imprescritível e impenhorável.

A legislação enumera taxativamente aquilo que considera como direito moral de autor, os quais, pela sua importância, merecem ser aqui referidos tal qual previsto no art. 24 da Lei de Direitos Autorais (BRASIL, 1998):

- reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
- ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
- conservar a obra inédita;
- assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-la, como autor, em sua reputação ou honra;
- modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
- retirar de circulação a obra ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;
- ter acesso exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

Todos esses direitos permanecem com o autor até a data do seu falecimento, sendo transmitidos, a partir de então, aos seus herdeiros, os quais passarão a ser os responsáveis pela obra como se fossem o próprio autor. Ao contrário do direito ao nome, imagem, entre outros, relacionados à personalidade, o direito moral de autor só existe se o autor criar uma obra intelectual que preencha os requisitos legais para obter a proteção.



Fique atento

A essência do direito moral de autor é a proteção e a preservação da relação do autor com a sua obra, instrumentalizada com ferramentas para, basicamente, regular e garantir a indicação da autoria, a circulação da obra e a alteração da obra da forma como melhor entender para defender a sua personalidade insculpida na obra intelectual. Trata-se de um direito, pois dedicado a tutelar o esforço criativo do autor.

Direito patrimonial de autor

Ao lado do direito moral de autor está o direito patrimonial, o qual visa, assim como os demais direitos que compõem a propriedade intelectual, permitir o aproveitamento econômico da obra (art. 28) (BRASIL, 1998). O autor, diga-se, não é obrigado a explorar a obra economicamente, tanto é que está regulado na legislação o direito em manter a obra inédita. Apesar disso, é cada vez menor o número de autores que preferem manter o ineditismo das suas criações intelectuais, a não ser por uma questão estratégica, como ocorre no caso de livros e álbuns musicais, por exemplo.

Uma das garantias resguardadas ao autor é o direito exclusivo de usar, fruir e dispor da sua obra intelectual. Todavia, se ele quiser auferir vantagem financeira, a lei o autoriza a fazer isso sob qualquer forma validamente prevista em lei e ainda exemplifica algumas modalidades à disposição do autor, sempre dependendo, é claro, da autorização prévia e expressa.

Quando houver autorização do autor para um terminado tipo de uso, ela jamais poderá ser interpretada de forma extensiva, pois as modalidades disponíveis são independentes entre si, necessitando, se for o caso, de novas autorizações junto ao autor.

Assim como o direito moral de autor, o direito patrimonial também é transmitido após o falecimento do criador, porém ele perde a característica da

perpetuidade, adquirindo o caráter temporário do direito, o qual passará a ter duração de 70 anos contados a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte àquele do falecimento. Passado esse período, o direito patrimonial passará a pertencer ao domínio público, não havendo mais necessidade de autorização prévia e expressa para que terceiros adquiram o proveito econômico com o uso da obra.



Fique atento

O art. 44 da Lei de Direitos Autorais conta o prazo de duração do direito patrimonial de autor de forma diferente para obras audiovisuais e fotográficas.

Portanto, o direito patrimonial de autor está ligado, em certa escala, ao direito de propriedade e à característica econômica da obra intelectual.

Titularidade dos direitos autorais

Percorridos os institutos basilares do direito autoral, estamos aptos, agora, a identificar quem é e quem pode ser titular de um direito autoral, considerando, especialmente, a condição de inalienabilidade do direito moral de autor.

Aliás, já iniciamos afirmando que o autor não é o mesmo que o titular de direitos autorais. O **autor**, de acordo com a lei, é apenas a pessoa física (art. 11) (BRASIL, 1998). Quem cria é o ser humano; logo, somente ele, sem restrição de sexo, de idade ou de mentalidade, pode ser autor de uma obra intelectual protegida.

A titularidade de direito autoral, por seu turno, pode ser tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Muitos doutrinadores dizem que a Lei de Direitos Autorais privilegiou muito mais o titular de direitos autorais do que o autor, baseado no momento histórico e nos bastidores do projeto de lei, que culminou com a promulgação da Lei nº. 9.610/1998. Por outro lado, também existem aqueles que justificam o maior número de regras ao titular por uma questão de necessidade de regulação, ainda que não exaustiva, da circulação econômica da obra autoral.

Contudo, a doutrina logo se empenhou em classificar a titularidade do direito autoral a partir da forma de aquisição. A titularidade originária, segundo estabelecido, é aquela adquirida a partir da criação de espírito materializada dentro dos requisitos e fora das exceções legais, representada pelo autor pessoa física. A titularidade derivada é aquela decorrente da transferência do direito moral de autor mediante sucessão hereditária e do direito patrimonial via modalidades jurídicas legalmente previstas, podendo ser exercida tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica.

Identificado quem são os titulares, resta-nos saber como a lei dispõe sobre a transferência dos direitos autorais e quais as exigências.

Transferência da titularidade

A transferência dos direitos autorais está regulada na Lei de Direitos Autorais e permite que ela ocorra de forma parcial ou total, tanto pelo autor quanto pelos sucessores, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, além disso, exemplifica os meios de transferência (licença, concessão, cessão), deixando claro que se permite qualquer outro meio admitido em Direito como forma de transferência.

Existem, entretanto, limitações impostas pela legislação no que diz respeito à transferência dos direitos autorais, todas elas relacionadas no art. 49, estando a principal delas no primeiro inciso, que faz a ressalva de que a transferência compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral. Na linha do que já analisamos, o direito moral de autor é inalienável, ou seja, mesmo que o autor queira transferi-lo a um terceiro, uma eventual concretização será nula de pleno direito.

Outro ponto importante a ser observado é que a transferência de direitos só admite a estipulação de direitos mediante contrato escrito, não estando albergada pela lei qualquer outra modalidade adotada. Nesse contrato, deverão estar previstas, no detalhe, todas as estipulações acordadas entre as partes, pois os contratos envolvendo direitos autorais são interpretados restritivamente.

Em suma, existem diversas formas de o autor (ou do titular) aproveitar comercialmente os direitos conferidos a uma obra intelectual, auferindo vantagens patrimoniais por meio do talento em criar obras de cunho artístico, literário ou científico, sendo primordial o conhecimento das regras que envolvem a matéria.

Referências

BRASIL. *Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 02 fev. 2018.

PIMENTA, E. S. *Código de direitos autorais e acordos internacionais*. São Paulo: LEJUS, 1998.

Leituras recomendadas

BARBOSA, D. B. *Direito de autor:* questões fundamentais de direito de autor. Porto Alegre: Lumen Juris, 2013.

BRANCO, S.; PARANAGUA, P. *Direitos autorais*. Rio de Janeiro: FGV, 2009.

NEVES, A. H. *Direito de autor e direito de imagem:* à luz da Constituição Federal e do Código Civil. Curitiba: Juruá, 2011.

PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.

unidade
2
V.1 | 2023

Parte 2

Software: Evolução e Modalidade de Registro

O conteúdo deste livro é disponibilizado por SAGAH.
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Software

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir software e a sua evolução.
- Diferenciar o registro de software de outras modalidades de registro de propriedade intelectual.
- Analisar o procedimento de registro de software junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Introdução

A proteção dos direitos autorais e patenteáveis de software é um tema ainda em construção na doutrina jurídica. Ainda que a Lei nº. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, tenha dado passos importantes para a sua consolidação como um ramo do direito autoral, há a possibilidade de registro de alguns elementos dessa figura como patente segundo as próprias orientações do INPI.

Neste capítulo, você vai ler a respeito do conceito de software e das suas evoluções, das características do seu registro e do procedimento pelo qual ocorre.

Conceito de software

O conceito de software hoje é facilmente identificado pela figura dos **aplicativos**, programas de computação — presentes nos nossos celulares, televisores, tablets, relógios, etc. — destinados ao atendimento de alguma necessidade de mercado. No entanto, a sua autonomia conceitual é relativamente nova em relação às ciências computacionais. Segundo Bertrand (1996, p. 15):

> Durante os seus vinte primeiros anos de existência, a indústria da informática era essencialmente baseada na fabricação e na venda do equipamento (*hardware*). Aliás, até 1970 os programas (*software*) eram considerados

> apenas "acessórios" dos computadores e não eram fabricados de uma maneira autônoma. Na época, compravam-se os computadores sem a preocupação com os programas com os quais iam ser utilizados.

Dessa forma, ao adquirir um **computador**, o consumidor esperava encontrá-lo operando as diversas funcionalidades divulgadas pelo seu desenvolvedor, estando atrelados novos serviços a uma nova máquina. Dessa forma, a noção de atualização de funcionalidades a partir da simples troca de programas era completamente fora de propósito ao olhar dos desenvolvedores e juristas nesse primeiro momento, motivo pelo qual o desenvolvimento de software seria protegido pela patente do maquinário ao qual estava vinculado como simples acessório. Essa concepção seria colocada em cheque com a evolução da indústria (BERTRAND, 1996, p. 15):

> (Na década de 1990) o *software* é para a informática o que a fita de vídeo é para o aparelho de videocassete. Não é mais um acessório: é "o alimento" e ao mesmo tempo "o motor" da máquina. É o elemento que determina as funções da máquina e que permite assim satisfazer ou não as necessidades de seu usuário. O usuário escolhe os programas em razão de suas funcionalidades e esta escolha vai muitas vezes ditar também a do equipamento no momento em que o programa selecionado só tiver a capacidade de rodar em uma plataforma específica. A existência e a qualidade dos programas se tornaram elementos essenciais do mercado de informática.

Assim, a liberdade de escolha do consumidor tornou-se possível pela liberdade de instalação de softwares em determinados aparelhos ou hardwares, independentemente da configuração original da máquina a partir da aquisição de mídias, como CDs, DVDs e, mais tarde, discos de *Blu-ray* contendo programas de computação, ou mesmo músicas ou vídeos para reprodução nesses aparelhos.

A partir dessa independência relativa do software em relação ao hardware, no entanto, a proteção das patentes relacionadas ao hardware passou a perder força em relação ao software, enquanto os seus processos criativos se distanciaram, criando empresas especializadas em outro elemento computacional.

Foi nesse momento evolutivo que surgiram as primeiras discussões jurídicas sobre o regime adequado de proteção dessa figura, que se encontra entre o **regime de patentes**, relacionado às invenções, e o **regime de direitos autorais**, vinculado classicamente a obras artísticas e registros literários na sua expressão registral, não abrangendo as ideias ou os processos criativos em si pela dificuldade de cadastrá-los.

Segundo Bertrand (1996, p. 24):

> [...] já no início dos anos setenta, os juristas europeus começaram enfim a questionar a necessidade de proteger juridicamente os programas, e assim, a extensão possível do direito autoral a esses programas. A opinião dos juristas foi rapidamente dividida. Enquanto já em 1971, o professor alemão Eugen Ulmer defendia a "proteção possível dos programas de computador pelo direito autoral" [...] ao passo que outros juristas dentre os quais o professor Robert Plaisant, eram por sua vez mais do que cépticos quanto à extensão do direito autoral aos programas, salientando a ausência de "caráter literário ou artístico" dos mesmos e o "caráter inadaptado" desse tipo de proteção.

A partir das discussões entre as limitações dos institutos clássicos de proteção de propriedade industrial, a criação de um conceito *sui generis* ou próprio de proteção foi proposta. No entanto, na época da discussão internacional, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) acabou optando por uma solução que enquadrasse a categoria em tratados já assinados pelos seus integrantes, de modo que o modelo adotado atualmente é uma aproximação dos direitos autorais previstos no Tratado de Berna.

É nesse sentido que conclui Silveira (2014, p. 63), que:

> Mantém a Lei nº. 9.609/98 o mesmo sistema da lei anterior — universalmente adotado até agora — de assemelhar o direito sobre tratamento da informação ao direito de autor sobre a forma de expressão, submetendo o direito do criador de *software* às normas gerais da lei autoral (Lei nº. 9.610, de 19.02.1998). É importante ressaltar que a Lei de Propriedade Industrial exclui, expressamente, "programas de computador em si", da tutela por meio de patentes (art. 10, V, da Lei n 9.279/96).

Assim, a norma brasileira conclui uma jornada iniciada nas origens do software enquanto parte necessariamente atrelada ao seu hardware de origem, protegida pela patente do último para proteger o software como elemento autônomo e autoral.

Nesse sentido, o **conceito de software** trazido pela Lei nº. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, é construído como:

> [...] a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados (BRASIL, 1998).



Fique atento

Independentemente do suporte das instruções organizadas que fazem o hardware operar de determinada maneira, seja em suporte físico, como nos primeiros computadores, ou em suporte virtual, como é o caso da nuvem, atualmente esses dados, organizados na forma de comandos específicos que fazem máquinas realizarem as tarefas das quais necessitamos, são programas de computador ou software.

Esse conceito se molda inclusive à sua modalidade mais contemporânea na forma dos **aplicativos multiplataforma**, que abrangem mais de uma máquina e que passaram a assumir de vez a sua natureza imaterial com finalidade própria, independentemente do hardware de origem, uma vez que a sua proteção se encontra na sua originalidade e distinção conceitual, não mais em um construto de propriedades distintas e úteis.

Distinções e semelhanças da proteção do software e outros gêneros de propriedade intelectual

A proteção do software enquanto propriedade intelectual, como visto, em um primeiro momento, assemelha-se à proteção de patentes e, em outro momento, com direitos autorais. Essa situação é derivada da mobilidade do software em relação ao hardware de origem, conforme as ciências computacionais evoluíram de um conceito de mercado baseado em aparelhos (hardware) para focar em aplicativos (software) que funcionam em aparelhos diversos.

O sistema de patentes é o primeiro sistema legal a proteger invenções, criado oficialmente em Florença, tendo ocorrências anteriores, como ensina Canalli e Silva ([2011], p. 745):

> Com o tempo, os homens foram percebendo que as invenções são necessárias ao progresso e que devem ser encorajadas, dando algumas vantagens financeiras e de exploração aos inventores. Embora na colônia grega de Sybaris (720–510 a.C.) tenham sido prometidos privilégios de um ano a quem desenvolvesse receitas culinárias ou artigos de luxo, a primeira patente de invenção foi concedida somente em 1421 pelo Conselho dos Lordes da República de Florença. Este privilégio foi concedido ao engenheiro, arquiteto e inventor Filippo Brunelleschi, por um prazo de três anos, pela construção de uma embarcação de carga (Il Badalone) que deveria transportar mármore pelo rio Arno.

Nas suas origens, assim como na atualidade, o sistema de patentes se preocupa com o monopólio de uso e produção de determinada invenção com potencial industrial (reproduzível em escala) e com utilidade para o mercado. O privilégio de monopólio em determinado território torna a atividade inovativa interessante ao criador, uma vez que os seus custos são elevados; por outro lado, a outorga de patente ao inventor traz credibilidade à sua inovação aos olhos do mercado, sinalizando que aquele inventor possui produto ou processo de interesse para a coletividade.

O sistema de patentes viria a ser complementado pelo sistema de direitos autorais em relação a obras de cunho lúdico, como a literatura, o teatro e outras áreas culturais, conforme ensina Cavalheiro (2001, p. 212-213):

> A primeira lei conhecida sobre direitos de autor apareceu na Inglaterra em 1709, baixada pela Rainha Ana (*Copyright Act* = Direito de cópia ou reprodução), [...] Em 1735, na Inglaterra, foi adotada outra lei, agora para resguardar a arte do desenho e que estabelecia a proibição de ser publicada ou importada, para fim de comércio, qualquer estampa de natureza histórica ou não, cujo autor, desenhista ou proprietário, não permitisse por escrito, a divulgação da mesma. Nos reinados de George II (1739) e George III (1766, 1775 e 1777) foram introduzidas ampliações e aperfeiçoamentos nas legislações existentes.

Apesar de a proteção dos direitos dos autores remontar à invenção da imprensa e à possibilidade de cópia facilitada de obras literárias e gravuras, a legislação tardou a tutelar, de maneira organizada, esses direitos, espelhando-se nos direitos de patente, mas limitando-se à proteção da expressão gráfica das obras, não abrangendo as ideias e os projetos que lhes deram origem.

Portanto, enquanto o sistema de patentes tradicionalmente abarcou invenções e modelos de utilidade — como processos industriais voltados à aplicação industrial, abrangendo desde a concepção do produto ou processo de fabricação até sua manifestação física —, o direito autoral tradicionalmente focou na manifestação do processo criativo presente na obra, não abrangendo os processos e as ideias por trás da obra, como uma forma de manter os processos criativos no domínio cultural da humanidade.

Ao tratarmos de software, logo, a proteção das patentes, para alguns doutrinadores, demonstra ser excessiva no sentido da impossibilidade de cópia de processos criativos de interesse do mercado da inovação durante o tempo de exclusividade do autor. Por outro lado, a exclusão dos projetos da proteção autoral de software representa uma quebra de incentivos para a manutenção dos processos únicos da sua criação, tornando a preservação o seu principal diferencial. Isso deixou o processo de *design* ou planejamento à mercê de

copiadores, enquanto os códigos em si, protegidos pelo sistema de direitos autorais, poderiam ser replicados em linguagem distinta.

Nesse sentido, instrui o manual do usuário do INPI:

> Nas décadas de 70 e 80 muito se discutiu a respeito do tipo de proteção a ser empregada para a recente indústria de *software*, fundamental para o contínuo aprimoramento da computação. O principal tema dos debates era o tipo de proteção mais adequada aos *softwares*: se a lei de direito autoral (*copyright*) ou a lei de propriedade industrial (patentes). Foi escolhida a lei de direito autoral (*copyright)*. Diversos países são hoje signatários da Convenção de Berna (Proteção de obras literárias e artísticas), incluindo o Brasil desde 1922, que adota na sua Lei nº 9.609/98 esta modalidade de proteção intelectual. A lei de *software* então passou a ser um ramo da lei do direito autoral.
> A lei de *software* e a lei de propriedade industrial (LPI) oferecem diferentes modos de proteção. A proteção dada pela primeira abrange apenas as expressões contidas no código utilizado, não os procedimentos ou métodos. Estes podem ser protegidos pela LPI, considerada uma proteção mais abrangente (BRASIL, 2017, p. 4).

Assim, mesmo que a comunidade internacional tenha resolvido optar pela adoção do sistema de direitos autorais, menos protetivos ao software enquanto expressões contidas no código utilizado, conforme depreendemos da leitura da Lei nº. 9.609/1998, é possível utilizarmos o sistema de patentes para resguardar os processos e as ideias que levaram à sua criação. Para tanto, devemos observar que esses processos e ideias obedecem aos critérios de novidade e aplicabilidade industrial.

Tal qual a proteção dos direitos autorais é "a proteção aos direitos relativos ao programa de computador independe de registro". No entanto, registrar o programa no INPI garante maior segurança jurídica ao seu detentor, conforme o manual do usuário:

> [...] caso haja, por exemplo, demanda judicial para comprovar a autoria ou titularidade do programa. Além disso, a proteção não é territorial como no caso das patentes, mas sim, sua abrangência é internacional, compreendendo todos os 175 países signatários da Convenção de Berna (1886) (BRASIL, 2017, p. 5).

Assim, embora a Lei nº. 9.609/1998 tenha adotado o sistema de direitos autorais, com a vantagem de proteção do direito de exploração exclusiva dos códigos expressos no programa por 50 anos, é possível usarmos a lei de patentes em relação às ideias e aos processos inovadores que levaram à sua existência,

desde que observados os requisitos de novidade e aplicabilidade industrial e o menor prazo de exploração exclusiva, este de 20 anos a partir do registro.



Fique atento

É uma boa estratégia de proteção, conforme indicado pelo próprio INPI, buscar amparo nas duas legislações: assegurar a posse exclusiva dos procedimentos ou do método pelo sistema de patentes e garantir a autoria dos trechos relevantes do código pelo registro de software. Ambos os pedidos são depositados junto ao INPI.

Procedimento de registro de software no Brasil

O registro do software, seja por meio do sistema de direitos autorais especial regido pela Lei nº. 9.609/1998, seja pelo sistema de patentes, hoje é realizado por meio do INPI, de forma eletrônica.



Link

Em razão do requisito da novidade, o registro de patente deve ser precedido por uma busca prévia nos bancos de dados de patentes. Esse serviço é realizado pelo próprio INPI.

Segundo o INPI: "Mesmo não sendo obrigatória, a busca é um importante indicativo para decidir se você entra com o pedido ou não. Assim, para avaliar se o pedido atende aos requisitos de patenteabilidade, é aconselhável fazer uma busca prévia". Para realizá-la, acesse:

https://goo.gl/5i9nGD

O pedido é realizado por meio de formulário eletrônico de registro de programa de computador (e-RPC) ou e-Patentes, disponível no portal do INPI — www.inpi.gov.br —, no qual podemos realizar um cadastro para habilitação no e-INPI, nos termos da Resolução nº. 25, de 18 de março de 2013.

No portal, serão gerados *login* e senha, utilizados para a emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU), além de demais solicitações de serviços a serem executados pelo INPI.

Todos serviços relativos ao e-RPC e e-Patentes podem ser solicitados, pelo titular ou seu procurador, ao INPI, mediante preenchimento do formulário eletrônico. Entende-se por titular aquele que possui os direitos patrimoniais do programa de computador e que vai instruir o pedido de e-RPC ou e-Patente no INPI, podendo ser nomeado um procurador. A Figura 1 mostra as fases do processo de registro de marca.

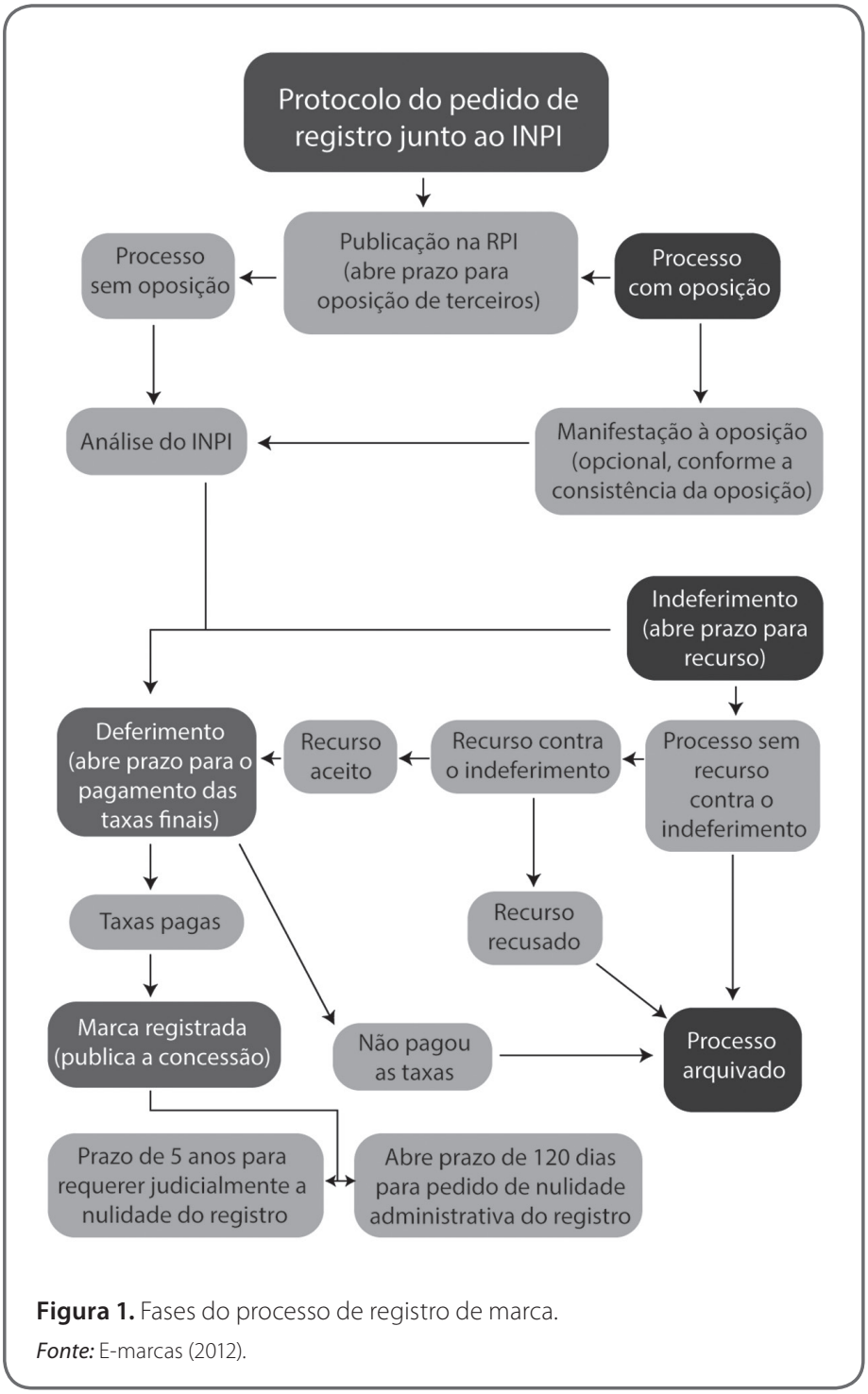


Figura 1. Fases do processo de registro de marca.

Fonte: E-marcas (2012).

O sistema verifica a validade da assinatura digital do titular do direito no documento de Declaração de Veracidade (DV), para o e-RPC. Além disso, o requerente deve realizar o pagamento das taxas via GRU. Já no caso de patentes, é necessário:

- conteúdo técnico, com relatório descritivo, quadro reivindicatório, listagem de sequências (para pedido da área biotecnológica), desenhos (se for o caso) e resumo;
- comprovante de pagamento da GRU.

O solicitante do registro, seja ele o próprio interessado (titular do direito) ou seu procurador, deverá assinar digitalmente (certificado digital ICP-Brasil) o documento DV eletrônico, disponível para *download* na GRU ou no formulário eletrônico e-RPC, que será disponibilizado na íntegra com as informações do solicitante, seja ele o titular do direito ou do procurador.

No caso de o titular do direito ser uma pessoa jurídica, tanto a emissão da GRU quanto a assinatura digital no documento DV, e/ou documentos de patente devem ser feitas pela mesma pessoa jurídica, nunca por uma pessoa física. Já no caso de o titular do direito ser uma pessoa física, os procedimentos devem ser feitos pela mesma pessoa física, nunca por uma pessoa jurídica.

Se houver um procurador, o titular de direito atuará como outorgante e é ele que assina digitalmente a procuração eletrônica. O procurador, ou seja, o outorgado, assinará digitalmente o documento eletrônico: DV e/ou pedido de patente. Nesse caso, compete ao procurador a emissão da GRU utilizando o seu *login* pessoal e senha, definindo, no ato da instrução da GRU, a identificação do seu cliente.



Fique atento

O procedimento de RPC é protegido pela função criptográfica *hash,* que é um algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico, de modo que um perito técnico possa comprovar que não houve alteração nesse documento desde a época em que este foi transformado. Assim, uma simples alteração nesse documento acarretará uma alteração do resumo *hash* original, desconstituindo, assim, a prova de integridade do depósito do programa de computador.

Para realizar o depósito de RPC, é necessário promover a transformação, em resumo digital *hash*, dos trechos do programa de computador e de outros dados que considerar suficientes e relevantes para identificá-lo, ficando a responsabilidade da guarda do objeto com o titular do direito, pois essa é sua propriedade intelectual e deve ser preservada na sua forma original e em ambiente seguro.



Saiba mais

O *hash* é uma prova eletrônica que pode ser obtida a partir de um único arquivo (arquivo de entrada), como, por exemplo, arquivos com extensão .pdf, .txt, .zip, .rar, entre outras. Esse arquivo de entrada é transformado em um resumo digital *hash* (arquivo de saída, de tamanho fixo), utilizando uma função *hash*. Note que, no caso de haver muitos arquivos, podemos utilizar um compactador de arquivos (por exemplo, WinZip, WinRAR). É fundamental que esse resumo digital *hash* possa ser conferido pelo perito do juiz (em caso de comprovação de autoria/titularidade, por exemplo), tendo como base o código-fonte (arquivo de entrada) guardado em sigilo pelo titular do direito.

O documento digital (arquivo) pode ser armazenado na forma mais apropriada e conveniente para o titular do direito. Pode armazená-lo em CD-ROM, DVD, disco rígido, nuvem, *pendrive* ou outro meio de armazenamento seguro, da sua confiança, pelo tempo que o titular entender necessário para a manutenção do seu direito autoral, sendo que esse tempo poderá ser de até 50 anos.

É recomendado ao titular que organize e documente a guarda do arquivo (mantendo cópias de segurança), assim como do certificado de registro (que também é um arquivo assinado pelo INPI), de modo a recuperá-lo facilmente quando for do seu interesse.

Cada registro no INPI possuirá um *hash* único, que validará, quando necessário, a autenticidade do software (arquivo) guardado pelo titular. Ainda, o titular pode optar pela autorização à obra derivada, que constitui a criação intelectual nova resultante da transformação da obra originária. O direito autoral no Brasil, previsto nos tratados internacionais, define que a utilização da obra depende de autorização prévia e expressa do autor da obra originária.

Caso o programa de computador objeto do pedido de registro seja derivado de outro, o campo "Derivação Autorizada" deverá ser preenchido com as informações necessárias atinentes ao software que o originou. O campo é de livre preenchimento.

Uma vez protocolado o pedido junto ao INPI, é aberto o prazo à oposição de terceiros, observando o devido processo administrativo por meio dos princípios da publicidade e do contraditório. No caso de haver ou não oposição, o pedido será analisado pelo INPI. Se deferido, abre-se o prazo para o pagamento das taxas administrativas finais; se indeferido, abre-se o prazo para recurso, que pode ser deferido (caso deferido, abre-se o prazo para pagamento das taxas administrativas finais) ou indeferido (ocasião em que é arquivado o processo).

Uma vez pagas as taxas finais, será publicada a concessão de direitos autorais ou patente ao titular dos direitos e são abertos prazos de 5 anos para requerimento judicial de nulidade do procedimento, se for o caso, ou de 120 dias no caso de nulidade administrativa do procedimento.



Saiba mais

O RPC em sete passos:

- acessar o portal do INPI;
- fazer um cadastro, no qual serão criados *login* e senha;
- utilizar o módulo GRU para emissão do boleto de pagamento;
- baixar o documento DV e assiná-lo digitalmente;
- pagar a GRU;
- acessar o formulário eletrônico e-RPC no portal do INPI, preenchê-lo e anexar o documento DV e procuração — se for o caso, assinada digitalmente por quem de direito;
- conferir as informações declaradas;
- enviar o formulário eletrônico e-RPC, quando então será gerado o número de pedido.

Referências

BERTRAND, A. *A proteção jurídica dos programas de computador*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Programa de computador:* manual completo. 2017. Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/programa-de-computador/programa-de-computador-manual-completo>. Acesso em: 9 jan. 2018.

BRASIL. *Lei nº. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998*. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. 1998. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm>. Acesso em: 8 jan. 2018.

CANALLI, W. M.; SILVA, R. P. *Uma breve história das patentes:* analogias entre ciência/tecnologia e trabalho intelectual/trabalho operacional. [2011]. Disponível em: <http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2018.

CAVALHEIRO, R. da C. R. História dos direitos autorais no brasil e no mundo. *Cadernos de Direito*, v. 1, n. 1, 2001. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/view/896/415>. Acesso em: 8 jan. 2018.

E-MARCAS. *Protocolo do pedido de registro junto ao INPI*. 2012. Disponível em: <https://e-marcas.com.br/wp-content/uploads/2012/01/fluxograma_20121.png>. Acesso em: 9 jan. 2018.

SILVEIRA, N. *Propriedade intelectual*. 5. ed. Barueri: Manole, 2014.



PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.

unidade
2
V.1 | 2023

Parte 3

Transferência de Tecnologia

O conteúdo deste livro
é disponibilizado
por SAGAH.

SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Transferência de tecnologia

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Conceituar transferência de tecnologia.
- Identificar o contrato de transferência de tecnologia e as suas especificidades.
- Analisar o procedimento de registro de contrato de transferência de tecnologia.

Introdução

A transferência de tecnologia é o método pelo qual o detentor de direitos de propriedade intelectual os transfere, na sua totalidade ou parcialmente, para terceiros. Também configura a maneira como a propriedade intelectual se torna um bem comercial na sua plenitude por meio da sua negociabilidade.

Neste capítulo, você vai ler sobre o conceito de transferência tecnológica, o instrumento contratual de transferência tecnológica e as suas especificidades, bem como o seu registro administrativo.

Conceito de transferência de tecnologia

A transferência de tecnologia é o método pelo qual o detentor de uma propriedade intelectual transfere a totalidade ou parte do seu direito a uma terceira parte para que esta realize a exploração comercial.

Podemos dizer que a transferência tecnológica permite que as ideias inovadoras passem a se tornar produtos e/ou serviços, uma vez que, a partir do uso das ideias por parte de terceiros, elas passam a ocupar relevância no cenário social e econômico, com raras exceções em que a figura do inventor e do empresário se confundem. Além disso, a transferência tecnológica, por muito tempo, foi essencial para permitir que países em desenvolvimento obtivessem acesso às tecnologias desenvolvidas pelos países desenvolvidos

e, assim, estabelecessem relações comerciais avançadas com as tecnologias existentes naqueles territórios.

Uma vez que a transferência tecnológica se encontra no campo do direito das coisas — conforme o disposto no art. 83, III, do Código Civil e também na legislação específica, a exemplo do art. 5º da Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, "consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial" (BRASIL, 1996), e do art. 3º da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, "os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis" (BRASIL, 1998), na forma de direito de propriedade —, o instrumento cabível para a sua realização é um **contrato de cessão de direitos**.

Diferentemente das coisas em geral, que podem ser objeto de alienação completa, na forma do art. 1.228 do Código Civil, a propriedade intelectual — por guardar correspondência com direitos de personalidade do criador, direitos pessoais, conforme o art. 83, III, do Código Civil, na qualidade de extensão da sua própria vontade — resguarda alguns direitos especiais, chamados de **direitos morais do criador**, em respeito às características impostas pelo art. 11 do Código Civil, em que "Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária" (BRASIL, 2002).

Como exemplo desses direitos inalienáveis, podemos apontar o direito de indenização por **exploração indevida do objeto**, conforme art. 44 (BRASIL, 1996), que visa resguardar a visão do criador e os usos da obra realizados por terceiros cessionários. De forma mais clara, os direitos autorais estabelecem um rol de direitos morais do autor no art. 24 da Lei nº. 9.610/1998, em que o autor pode, a qualquer tempo (BRASIL, 1998):

- reivindicar a autoria da obra;
- ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo do autor na utilização da obra;
- conservar a obra inédita, se assim o quiser;
- assegurar a integridade da obra, opondo-se a modificações ou prática de atos que possam prejudicá-la ou atingi-la em sua reputação ou honra;
- modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
- retirar de circulação a obra ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando implicarem afronta à sua reputação e imagem;
- ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para preservar a sua memória por meio fotográfico ou semelhante.

Dessa forma, o contrato que tiver como objeto a transferência de propriedade intelectual deve observar as restrições da sua alienabilidade, que restringe a concessão de direitos parciais sobre a obra intelectual, resguardados os direitos morais do seu criador.

Por essas características especiais, a maioria dos contratos de alienação de direitos de propriedade intelectual é chamada de contratos de **cessão de direitos** ou de **licença**; estes últimos não se confundem com a outorga de direitos públicos a entes privados do Direito Administrativo, igualmente chamados de licenças, mas que possuem características análogas, mas entre o ente público ou privado detentor da propriedade intelectual e o ente público ou privado que é usuário.

Além disso, como a transferência de tecnologia é uma extensão da propriedade intelectual originária, assim como a que necessita de procedimento administrativo registral para ser oposta a terceiros no órgão competente, a transferência de direitos de propriedade intelectual também deve ser registrada no mesmo órgão para que gere efeitos oponíveis contra todos.

Assim, aquele contrato que cede ou licencia o uso, a comercialização ou a reprodução de direitos de patente, por exemplo, deve ser registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), assim como os contratos de cessão ou licença de direitos sobre novos cultivares devem ser registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio do Sistema Nacional de Proteção de Cultivares.



Fique atento

A transferência de tecnologia é uma espécie de contrato de alienação parcial de direitos, mediante cessão ou licença de uso por parte do detentor da totalidade desses direitos. Ou seja, o criador que resguarda, de forma compulsória, os seus direitos morais, como a vinculação do criador à sua invenção e a possibilidade de impedimento de uso inadequado da coisa criada se causar problemas à sua reputação, deve ser registrado no órgão competente para que gere efeitos *erga omnes*.

Contratos de transferência de tecnologia por objeto

Como visto, a transferência de tecnologia é o meio pelo qual a propriedade intelectual passa, em parte, da propriedade do criador para o uso legal ou contratualmente restrito do cessionário ou licenciado.

Essa transferência, no entanto, não ocorre da mesma maneira em todas as espécies de propriedade intelectual, como visto, seguindo a sorte da categoria específica de propriedade intelectual originária quanto à sua forma, ao seu local de registro e aos seus procedimentos específicos.

No caso das patentes, por exemplo, os instrumentos contratuais cabíveis estão previstos na Lei nº. 9.279/1996, que regula a propriedade industrial no Brasil, estando a transferência de tecnologia prevista no capítulo VII "Da Cessão e das Anotações" e na seção I da "Licença Voluntária". O art. 58 registra a indivisibilidade do conteúdo da patente em si, que poderá ser cedida total ou parcialmente, com anotações do INPI da cessão, qualificação do cessionário, bem como qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou patente e alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Conforme o art. 61, para tanto, o titular da patente ou depositante poderá celebrar contrato de licença para a sua exploração, podendo o licenciado ser investido de todos ou parciais poderes. Já o art. 62 confirma a competência do INPI para a sua averbação e o condiciona para que produza efeitos em relação a terceiros, a partir da publicação das mencionadas anotações (BRASIL, 1996).

Além do licenciamento consensual ou contratual, também são possíveis (BRASIL, 1996):

- transferência de **tecnologia compulsória** ou **licença compulsória**, prevista no art. 68 da Lei de Propriedade Industrial, conforme a abusividade da exploração econômica realizada pelo titular, caso comprovada nos termos dessa lei, mediante decisão administrativa ou judicial;
- não exploração do objeto da patente, falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto;
- falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação;
- comercialização que não satisfizer as necessidades do mercado.

No caso, a licença somente poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno.

Além disso, a licença compulsória poderá ser concedida quando se caracterizar dependência de uma patente em relação a outra, bem como quando o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior e o titular não realizar acordo com o titular da patente

dependente. As mesmas disposições são aplicáveis, no que couber, ao desenho industrial, conforme o disposto no art. 121 da referida lei.

Já a marca pode ser objeto de cessão, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para o registro, conforme os arts. 134 e 135, que limitam a cessão à compreensão de todos registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos (BRASIL, 1996). Assim como ocorre nas patentes, o INPI fará as devidas anotações no registro da marca a partir da averbação do contrato, gerando efeitos a terceiros a partir da sua publicação. A cessão pode se dar por contrato de licença de uso da marca, sem prejuízo do direito do titular do controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. O art. 140 define a competência do INPI para a sua averbação.

Já no caso de direitos autorais, a Lei nº. 9.610/1998 prevê (BRASIL, 1998):

- a transferência dos direitos de autor em seu capítulo V, no qual o art. 49 prevê que os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos por ele ou seus sucessores, a título universal ou singular, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou outros meios admitidos no Direito, admitidas as limitações das restrições aos direitos morais do autor;
- a forma escrita do instrumento contratual ou pelo prazo máximo de 5 anos sem ela;
- a limitação geográfica ao país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário;
- a limitação às modalidades existentes à data do contrato;
- a interpretação restritiva do contrato, além disso, o art. 50 presume a onerosidade dessa transferência de titularidade.

A Lei nº. 11.484, de 31 de maio de 2007, que trata da topografia de circuitos integrados, dispõe, na sua Seção IX, das licenças e do uso não autorizado. Já o art. 44 prevê que o titular do registro de topografia de circuito integrado poderá celebrar contrato de licença para exploração, assim como o art. 45 prevê seu registro no âmbito do INPI (BRASIL, 2007).

A Lei do *Software* (Lei nº. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998) estabelece, no seu Capítulo IX, os contratos de licença de uso, comercialização e transferência de tecnologia, estabelecendo, em seu art. 9º, que o uso de programa de computador no Brasil é objeto de contrato de licença, podendo o documento fiscal de venda do produto ser utilizado para comprovação do seu uso regular (BRASIL, 1998b).

O art. 10 define que os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior (BRASIL, 1998b).

O § 1º estabelece como nulas as cláusulas que limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às disposições normativas em vigor, ou que eximam quaisquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor (BRASIL, 1998b). Além disso, o art. 11 estabelece a competência do INPI para o registro do contrato (BRASIL, 1998b).

Finalmente, a Lei nº. 9.456, de 25 de abril de 1997, que define a proteção de cultivares, estabelece, na sua Seção VII, as alterações no certificado de proteção de cultivar.

A mesma lei prevê, em seu art. 23, a transferência *inter vivos* ou sucessão legítima ou testamentária da titularidade da proteção de cultivar. Já no art. 24 prevê a necessidade de averbação no certificado de proteção expedido pelo Sistema Nacional de Proteção de Cultivares do MAPA (BRASIL, 1997).



Fique atento

Os contratos de cessão de licença de uso de propriedade intelectual são contratos onerosos, que, junto com a herança, são formas de transferência de tecnologia. São caracterizados pela transmissão de bens móveis de forma limitada quanto aos direitos morais do criador e devem ser registrados no INPI, no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC) ou no órgão de origem do seu direito de propriedade intelectual originário.

Procedimento de averbação de contratos de transferência de tecnologia

O procedimento administrativo de averbação de transferência de tecnologia — nas suas modalidades de patentes, marcas, topografia de circuitos integrados e software — está previsto na Resolução INPI nº. 199, de 7 de julho de 2017, sendo o procedimento específico dos cultivares e conhecimentos tradicionais relacionados, realizados respectivamente no SNPC do Ministério da Agri-

cultura e do Abastecimento e no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGEN) do MAPA.

São requisitos de admissibilidade de averbação ou registro e petições, previstos no art. 1º da Resolução INPI nº. 199/2017, os seguintes documentos (BRASIL, 2017):

- formulário de pedido de averbação com *login* por Cadastro de Pessoa Física (CPF) da parte ou do procurador;
- cada processo deve ter um único contrato, que poderá conter mais de uma modalidade contratual, sob pena de arquivamento do requerimento;
- cada processo deverá ter uma fatura ou mais de uma limitada ao número de 12;
- o requerimento de pedido de averbação ou de registro da petição ao processo poderá ser solicitado por qualquer uma das partes do contrato ou procurador com poderes para tal ato;
- comprovante de recolhimento da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU).

Caso o contrato contenha mais de uma modalidade contratual, deverá ser emitida e paga uma única GRU correspondente a todas as modalidades objeto do contrato, sob pena de exigência para apresentação do comprovante de pagamento da outra modalidade contratual. Além disso, deve conter procuração com poderes específicos para assinatura de contratos/aditivos quando o signatário do documento não for sócio, presidente, vice-presidente ou gerente, caso aplicável.

A procuração vigente da empresa requerente que outorgue poderes de representação perante ao INPI deve apresentar:

- caso emitida no exterior, ser notarizada no país de origem;
- contrato digitalizado com todos os seus anexos e traduzido para o português, se for o caso, com tradução juramentada dos documentos;
- fatura com número, data de expedição, descrição do serviço e período em que foi executado;
- valor e moeda de pagamento;
- razão social da empresa cessionária de acordo com o seu contrato social;
- razão social da empresa cedente;
- nome completo e cargo do signatário da fatura.

A partir do registro no sistema informatizado do INPI dos documentos requeridos, será realizado o exame formal e técnico dos contratos e das faturas juntadas.

O INPI analisará:

- a conformidade da documentação apresentada;
- o levantamento da titularidade e situação dos pedidos de direito de propriedade industrial;
- a vigência dos direitos de propriedade intelectual e de vigência dos direitos de propriedade industrial objeto dos contratos de cessão;
- a licença e sublicença de direito de propriedade industrial e topografia de circuito integrado e contratos de franquia.

Além disso, o exame técnico analisará:

- o objeto e as condições dos contratos de fornecimento de tecnologia e serviços de assistência técnica e científica;
- a situação dos pedidos de direito de propriedade industrial e de vigência dos contratos de franquia para emissão do certificado de averbação e de registro.

O prazo de vigência declarado do contrato e do certificado de averbação de registro obedecerá à vontade das partes no contrato, observados os prazos determinados pelo INPI quanto ao direito originário.

A decisão proferida pelo INPI relativa ao exame pode ser pela emissão do certificado de averbação ou de registro, quando:

- atendidas as condições gerais de admissibilidade do contrato e as condições necessárias dos campos constantes no certificado;
- formulação de exigência formal ou técnica quando não atendido pelo menos um dos itens das condições gerais de admissibilidade;
- indeferimento do requerimento ou arquivamento.

O prazo para a decisão é de até 30 dias contados da data de publicação da notificação de requerimento, sendo o prazo para cumprimento da exigência de 60 dias a contar da publicação da decisão na Revista da Propriedade Industrial.

Saiba mais

Para se cadastrar no e-INPI, basta acessar o site **https://goo.gl/RV8vfN** na página principal do portal do INPI (**https://goo.gl/EnuOl**), como indicado na figura a seguir. Esse cadastro é necessário para toda pessoa, física ou jurídica, que queira demandar serviços ao INPI, e funciona para todo o INPI. Uma vez criado o seu cadastro, o usuário terá acesso a todos os serviços oferecidos pelo INPI com o mesmo *login*, acessando o sistema e-Contratos com o *login* de pessoa física.



Referências

BRASIL. *Resolução PR nº. 199, de 07 de julho de 2017.* Dispõe sobre as Diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia. 2017. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>. Acesso em: 02 fev. 2018.

BRASIL. *Lei nº. 11.484, de 31 de maio de 2007.* Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores — PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital — PATVD; altera a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11484.htm>. Acesso em: 02 fev. 2018.

BRASIL. *Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o código civil. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 02 fev. 2018.

BRASIL. *Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 02 fev. 2018.

BRASIL. *Lei nº. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998*. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. 1998b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9609.htm>. Acesso em: 02 fev. 2018.

BRASIL. *Lei nº. 9.456, de 25 de abril de 1997.* Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm>. Acesso em: 02 fev. 2018.

BRASIL. *Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996.* Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 02 fev. 2018.

Leituras recomendadas

ARAÚJO, J. C. *A lei de proteção de cultivares:* análise de sua formulação e conteúdo. Brasília: CDI, 2010. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/3543>. Acesso em: 02 fev. 2018.

BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. *Guia básico de transferência de tecnologia*. 2017. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia>. Acesso em: 8 jan. 2018.

CANALLI, W. M.; SILVA, R. P. *Uma breve história das patentes:* analogias entre ciência/tecnologia e trabalho intelectual/trabalho operacional. [2011]. Disponível em: <http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2018.

CAVALHEIRO, R. da C. R. História dos direitos autorais no brasil e no mundo. *Cadernos de Direito*, v. 1, n. 1, 2001. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/view/896/415>. Acesso em: 8 jan. 2018.

SHERWOOD, R. M. *Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico*. São Paulo: EdUSP, 1992.

PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.

Parte 4

Fundamentos do Direito Penal Cibernético

O conteúdo deste livro é disponibilizado por SAGAH.

SAGAH SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Fundamentos do direito penal cibernético

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Conceituar direito cibernético.
- Explicar as leis brasileiras relacionadas ao direito cibernético.
- Elencar os tipos penais mais comuns no direito cibernético.

Introdução

O direito penal cibernético vem ganhando cada vez mais espaço no mundo jurídico, uma vez que os avanços tecnológicos se apresentam como imenso desafio para a legislação penal pátria vigente. Até o presente momento, ainda que existam aperfeiçoamentos do Código Penal e leis especiais, bem como a criação de novos tipos penais, resta uma grande lacuna na adequação da normativa penal frente ao avanço dos delitos que são cometidos no âmbito virtual. Nesse sentido, o crime cibernético passou a ser matéria recorrente entre os doutrinadores nos últimos anos, visto que o aumento de práticas delituosas e a dificuldade de controle e combate pelas forças jurídicas do Brasil aos crimes cibernéticos é assunto comum não apenas na vida cotidiana, mas nos tribunais. Com isso, desde o ano de 2012 algumas leis específicas à temática foram publicadas e demonstraram certo avanço legal em relação ao tratamento dos crimes cibernéticos pelo direito penal, sendo de relevante destaque a Lei nº 12.737, de 2012, intitulada Lei dos Crimes Cibernéticos.

Dessa maneira, verifica-se que os operadores do direito buscam maiores especificidades na legislação pátria e mecanismos de combate a delitos informáticos específicos. Sob a teoria geral do delito, o crime cibernético também deve se enquadrar no critério tripartite e, para ser considerado uma conduta criminosa, deve constituir uma ação típica, antijurídica e culpável. Ademais, ainda que expressamente tipificados na legislação pátria, delitos comuns cibernéticos como estelionato e fraude, além da invasão de dispositivo informático, encontram dificuldades de serem investigados e solucionados, uma vez que o ambiente virtual muitas vezes prejudica o rastreamento por parte dos profissionais de polícia no Brasil.

Neste capítulo, você conhecerá o conceito de direito cibernético e examinará o conteúdo dos principais documentos legais relacionados com o tema no Brasil. Além disso, estudará os tipos penais mais comuns no direito cibernético no país.

O conceito de direito cibernético

Para que o conceito de direito cibernético e, da mesma forma, de crime cibernético, seja compreendido de maneira mais delineada, é preciso entender a teoria geral do delito adotada pelo direito criminal no Brasil. Desse modo, as condutas vinculadas com as ações realizadas no campo virtual podem ser compreendidas como meras ações ou como delitos de natureza criminal.

Nesse contexto, a Lei de Introdução do Código Penal, Lei nº 3.914, de 1941, traz a seguinte definição de crime:

> [...] considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com pena de multa; contravenção, a infração a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente (BRASIL, 1941b, documento *on-line*).

Essa lei de introdução sem qualquer preocupação científico-doutrinária limitou-se apenas a destacar as características que distinguem as infrações penais, consideradas crimes, daquelas que constituem contravenções penais, as quais, como é possível detectar, restringem-se à natureza da pena de prisão aplicável. Ao contrário dos Códigos Penais de 1830 (artigo 2º, §1º) e 1890 (artigo 7º), o atual Código Penal em vigor, do ano de 1940, com reformas em anos seguintes, não define crime, deixando a elaboração de seu conceito à doutrina nacional. As experiências anteriores, puramente formais, eram incompletas e defeituosas, recomendando o bom senso e o abandono daquela prática (BITTENCOURT, 2013).

Todos os elementos estruturais do conceito analítico de crime adotado pela doutrina e jurisprudência — com especial destaque às cortes superiores do país, Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF) — indicam que crime é uma conduta **típica**, **antijurídica** e **culpável**. Assim, apesar das diversas classificações em relação aos crimes, a utilizada e reconhecida no Brasil é essa definição tripartida, ou tripartite, (BITTENCOURT, 2013; SANTOS, 2014).

O tipo, ou melhor, a **tipicidade** do delito, é a maneira como o princípio da legalidade no âmbito penal se apresenta no mundo dos fatos, uma vez que é a descrição abstrata de um fato real que a lei penal proíbe. Logo, quando um indivíduo pratica um ato atípico, mas a conduta do agente não se adequa à uma norma penal (aos tipos de crimes descritos na lei penal), diz-se que aquela conduta não é crime (LEBRE, 2015). O Código Penal traz expresso em seu artigo 121, por exemplo, que o ato de matar alguém é punível com pena de reclusão de 6 a 20 anos; portanto, o tipo penal é o ato de matar alguém (BRASIL, 1940). Contudo, se a legislação brasileira não indica que determinada conduta é um crime, ela não pode ser caracterizada como tal, do contrário, é indicada como conduta atípica ou não criminosa.

O segundo elemento que compõe a concepção de crime é a **antijuridicidade**, que pode ser compreendida como a ilicitude da conduta, ou seja, um comportamento que não é autorizado pela lei penal brasileira. Trata-se da contrariedade que se estabelece entre um fato típico e o ordenamento jurídico como um todo. Desse modo, ainda que o ato seja típico, se não estiver autorizado ou fomentado por outra norma jurídica, não se fala em ilicitude da conduta, ou seja, não se indica que a conduta é antijurídica. Caso a conduta esteja amparada por uma causa de exclusão da ilicitude (da antijuridicidade), como é o caso da legítima defesa ou do estado de necessidade, não se pode dizer que é um fato passível de punição (LEBRE, 2015). Se uma pessoa estiver, por exemplo, em eminente perigo durante a prática de um roubo e reagir, ferindo o autor do delito, essa conduta não é ilícita, visto que o indivíduo agiu em legítima defesa.

Por último, tem-se o elemento da **culpabilidade**. Entende-se por culpabilidade, ou conduta culpável, o juízo de reprovação que recai sobre a conduta do agente que tem, ou pode ter, a consciência da ilicitude do ato praticado e a possibilidade de agir em conformidade com as normas jurídicas (LEBRE, 2015). Digamos que, usando de seus conhecimentos técnicos, um profissional de tecnologia consegue acessar um banco de dados de cartão de crédito — ora, aqui mora a culpabilidade, pois racionalmente o indivíduo sabe que, se utilizar os dados sem autorização para obter vantagem financeira, virá a responder criminalmente por seus atos; porém, se não o fizer não será punido.

Esses mesmos três elementos essenciais à indicação de que uma conduta é criminosa podem ser aplicados para determinar quando uma atitude realizada via computador ou internet é considerada crime ou não. Nos casos em que a conduta não tenha esses três elementos, a concepção enquanto crime é afastada.

Nesse sentido, o direito cibernético é uma área do conhecimento jurídico que estuda as relações sociais na internet, englobando leis e tipificando condutas criminosas que são praticadas com a utilização de computadores ou por meio da tecnologia da informação de maneira genérica. O direito cibernético envolve desde *fake news* a fraudes eletrônicas, violações de direito autoral, divulgação de informações e de imagens sem autorização, entre tantas outras ações que podem ser praticadas no âmbito virtual. Partindo-se da concepção de direito cibernético e do conceito analítico de crime, chega-se à concepção de crimes cibernéticos, conceituados como todas as ações típicas, antijurídicas e culpáveis que são praticadas contra ou com o uso dos sistemas da informática. Nesse sentido, Schmidt (2014, documento *on-line*) abrange sob o conceito de crimes cibernéticos:

> A conduta atente contra o estado natural dos dados e recursos oferecidos por um sistema de processamento de dados, seja pela compilação, armazenamento ou transmissão de dados, na sua forma, compreendida pelos elementos que compõem um sistema de tratamento, transmissão ou armazenagem de dados, ou seja, ainda, na forma mais rudimentar; 2. O "crime de informática" é todo aquele procedimento que atenta contra os dados, que faz na forma em que estejam armazenados, compilados, transmissíveis ou em transmissão; 3. Assim, o "crime de informática" pressupõe dois elementos indissolúveis: contra os dados que estejam preparados às operações do computador e, também, através do computador, utilizando-se *software* e *hardware*, para perpetrá-los; 4. A expressão crimes de informática, entendida como tal, é toda a ação típica, antijurídica e culpável, contra ou pela utilização de processamento automático e/ou eletrônico de dados ou sua transmissão; 5. Nos crimes de informática, a ação típica se realiza contra ou pela utilização de processamento automático de dados ou a sua transmissão. Ou seja, a utilização de um sistema de informática para atentar contra um bem ou interesse juridicamente protegido, pertença ele à ordem econômica, à integridade corporal, à liberdade individual, à privacidade, à honra, ao patrimônio público ou privado, à administração pública, [entre outros].

A partir do conceito trazido na Convenção de Budapeste de Cibercrime de 2001, pode-se indicar que os crimes de informática são aqueles perpetrados via computadores, contra eles ou por meio deles, de maneira que a grande maioria dos delitos é praticada por intermédio do sistema de internet (SCHMIDT, 2014).

Didaticamente, os crimes cibernéticos, também denominados crimes virtuais, podem ser classificados como próprios (ou puros) e impróprios (ou impuros). Os classificados **crimes cibernéticos próprios** são aqueles em que o sujeito ativo usa o sistema informático do sujeito passivo, em que o computador, como sistema tecnológico, é utilizado como meio para o cometimento do delito (ALMEIDA *et al*., 2015). Essa categoria de crimes virtuais é voltada a bens jurídicos em que a norma penal protege a inviolabilidade das informações automatizadas, ou seja, os dados. Assim, incluem os delitos eletrônicos que são praticados por computador e/ou que se consumam por via eletrônica. Nos crimes próprios, a informática, a segurança dos sistemas, a titularidade das informações e a integridade dos dados são os objetos tutelados juridicamente (CARNEIRO, 2012).

Nesse âmbito, enquadra-se não apenas a invasão de dados não autorizados, mas também quaisquer interferências em dados informatizados, tal como:

> [...] invasão de dados armazenados em computador no intuito de modificar, alterar, inserir dados falsos, ou seja, que atinjam diretamente o ***software*** ou ***hardware*** do computador e só podem ser concretizados pelo computador ou contra ele e seus periféricos (ALMEIDA *et al*., 2015, p. 224).

Por sua vez, os **delitos cibernéticos impróprios** são os praticados por meio de computador usado como recurso para realização de atividades ilegais que alcançam todo o bem jurídico já tutelado, ou seja, são crimes já tipificados no âmbito jurídico penal e que agora são realizados via computador ou internet, usando o sistema de informática como meio para cometimento do crime, diferenciando-se pela não imprescindibilidade do computador para materialização do ato ilícito. Desse modo, tal ato pode ocorrer de diversas maneiras e não fundamentalmente pela informática para alcançar a finalidade almejada. É o que ocorre, por exemplo, no crime de pedofilia (ALMEIDA *et al*., 2015). Nesse sentido, (CARNEIRO, 2012, documento *on-line*):

> [...] os crimes eletrônicos impróprios [...] são aqueles em que o agente se vale do computador como meio para produzir resultado naturalístico, que ofenda o mundo físico ou o espaço "real", ameaçando ou lesando outros bens, não computacionais ou diversos da informática (CARNEIRO, 2012, documento *on-line*).

Tais crimes comuns — estelionato, extorsão, etc. —, os crimes cibernéticos também têm dois polos: um de sujeição passiva e outro de sujeição ativa. Em ambiente virtual, a imputação objetiva ao autor do delito e sua prova de materialidade são questões problemáticas, sendo difícil definir quem é o sujeito ativo do crime, já que, no mais das vezes, ocorre a ausência física do

agente. Ainda que seja genericamente simples compreender o que é sujeito passivo a partir da teoria do direito penal, identificar quem são esses sujeitos no mundo cibernético é um desafio para os agentes de investigação, mesmo traçando um perfil desses criminosos, de que maneira agem e quais são seus objetivos. Seu rastreamento é dificultado também porque informações como IP, *login* e senha, podem ser camuflados com dados inverídicos, o que dificulta a rápida identificação do sujeito ativo nas práticas delituosas no espaço virtual (ALMEIDA *et al*., 2015).

Do outro polo da relação estão os sujeitos passivos, que sofrem com a lesão virtual praticada por um sujeito ativo no ambiente virtual. Desse modo, podem ser sujeitos passivos pessoas físicas e jurídicas ou uma entidade titular de bem jurídico de direito público ou privado. O sujeito passivo pode ter bens desviados, seu patrimônio deteriorado ou mesmo ter informações violadas pela ação de um sujeito ativo.

Vale destacar também as condutas danosas atípicas, que são as ações praticadas por meio da rede mundial de computadores ou meios tecnológicos que causam transtornos ou prejuízos à vítima, mas que, pela inexistência de previsão legal em relação à ação cometida pelo sujeito ativo, não preveem punição na seara criminal. Porém, ainda que não haja punição no âmbito penal, o sujeito, quando identificado, pode ser responsabilizado no âmago civil, por exemplo, por meio da obrigação de pagamento indenizatório por danos. Para que essas questões sejam alcançadas pelo direito penal, além das disposições legislativas já existentes, é preciso haver melhor aprofundamento da matéria de crimes cibernéticos pela lei penal, com ampliação de tipificações específicas, diante da classificação de crimes cibernéticos abertos e crimes exclusivamente cibernéticos. Os crimes cibernéticos são classificados pela doutrina brasileira dominante como delito de natureza formal, posto que se consumam no momento da prática da conduta delitiva, independentemente da ocorrência do resultado naturalístico. Nesse sentido:

> Trata-se de crime comum (aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa), plurissubsistente (costuma se realizar por meio de vários atos), comissivo (decorre de uma atividade positiva do agente: "invadir", "instalar") e, excepcionalmente, comissivo por omissão (quando o resultado deveria ser impedido pelos garantes — art. 13, § 2º, do Código Penal), de forma vinculada (somente pode ser cometido pelos meios de execução descritos no tipo penal) ou de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio de execução), conforme o caso, formal (se consuma sem a produção do resultado naturalístico, embora ele possa ocorrer), instantâneo (a consumação não se prolonga no tempo), monossubjetivo (pode ser praticado por um único agente), simples (atinge um único bem jurídico, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada da vítima) (ALMEIDA *et al*., 2015, p. 227–228).

É preciso sublinhar que a comprovação da materialidade do delito criminal é essencial à persecução criminal. Se ela inexiste, está ausente o requisito mínimo para deflagração da ação penal, ou seja, a justa causa, sem possibilidade de que seja instaurada uma ação penal com o objetivo de punir o sujeito ativo que cometeu o ato ilícito de natureza cibernética.



Fique atento

Um relatório divulgado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento pôs o Brasil em 4º lugar no *ranking* mundial de usuários da rede mundial de computadores, com 59% de usuários conectados em sua população. É nesse contexto que o ordenamento jurídico penal brasileiro, seja pelo Código Penal, seja por legislações específicas, tende a se tornar um instrumento normativo cada vez mais elaborado e atualizado, com a finalidade de tipificar os crimes cibernéticos específicos. A sociedade civil e os profissionais do âmbito criminal clamam por legislação específica para o combate de delitos cibernéticos e meios de identificação desses criminosos, que ameaçam direitos básicos e trazem insegurança para o âmbito virtual (PADOVEZ; PRADO, 2019).

As leis brasileiras relacionadas ao direito cibernético

As ciências jurídicas têm de se adaptar às novas realidades da sociedade, e não seria para o direito cibernético. Com a revolução tecnológica e informacional, é necessário revisitar as práticas utilizadas para que as ciências jurídicas estejam de acordo com as novas tendências da vida cotidiana, o que inclui os ambientes informatizados que vêm sendo amplamente utilizados para a prática de condutas criminosas.

Partindo do pressuposto de que a rede mundial de computadores é um ambiente globalizado, os crimes cibernéticos se proliferam de maneira acelerada. Com a popularização da internet, surgiram indivíduos especializados em praticar crimes no ciberespaço:

> [...] um mundo de comunicação onde não é necessário haver a presença física do homem para construir a comunicação. Assim, a interconectividade e o espaço interligam pessoas, documentos e máquinas, considerando a internet como principal ambiente do espaço virtual (SANTOS; MARTINS; TYBUCSH, 2017, documento *on-line*).

São muitos os meios de acesso a informações e para delitos cometidos no âmbito virtual, incluindo crimes de natureza comum, como contra a honra, pornografia infantil, pedofilia, delitos contra o sistema financeiro, fraudes, extorsões, estelionatos, entre tantos outros. É nesse contexto que o Brasil busca se adequar às novas realidades ao editar leis específicas para tratar dessas questões, seja no Código Penal ou em legislações penais específicas. Nesse contexto, foram editados documentos legais com a finalidade de inibir novos crimes virtuais, como a Lei nº 12.735, de 2012, a Lei nº 12.737, de 2012, o Marco Civil da Internet e, muito recentemente, a Lei nº 14.155, de 2021.

Nos últimos anos, órgãos da polícia judiciária buscaram se aperfeiçoar frente ao crescimento vertiginoso de delitos cibernéticos praticados no país. Também houve a criação de delegacias especializadas, que buscam efetividade na individualização da autoria e materialidade delitiva. Nesse sentido, foi sancionada a Lei nº 12.735, de 2012, apelidada de Lei Azeredo, determinando aos órgãos de polícia judiciária a "criação de setores e equipes especializadas no combate à ação delituosa em rede de computadores, dispositivo de comunicação ou sistema informatizado", conforme dispõe seu artigo 4º (BRASIL, 2012a, documento *on-line*).

No mesmo ano, foi sancionada outra lei voltada aos delitos virtuais, a Lei nº 12.737, apelidada de Lei dos Crimes Cibernéticos, ou ainda Lei Carolina Dieckmann, que trouxe importantes alterações para o Código Penal (Decreto-lei nº 2.848, de 1940), formalizando e tipificando condutas delituosas no ambiente informático, constituindo os denominados crimes cibernéticos (ALMEIDA *et al*., 2015).

A tipificação dos crimes cibernéticos está prevista no artigo 1º da referida norma legal. Uma importante inovação trazida pela Lei nº 12.737/2012 foram as alterações na seção IV do Código Penal brasileiro, que trabalha com crimes contra a inviolabilidade de segredos, uma vez que acrescentou ao documento legal os artigos 154-A e 154-B. Esta lei criou o tipo penal "invasão de dispositivo informático" (BRASIL, 2012b, documento *on-line*).

O *caput* do artigo 154-A do Código Penal pode ser avaliado como o maior progresso trazido pela Lei nº 12.737/2012, cujo "objetivo principal é realizar o combate às principais práticas danosas, conhecidas por trazerem transtornos para quem se utiliza ou necessita dessas tecnologias" (ALMEIDA *et al*., 2015, p. 229).

O objetivo dos artigos inseridos no Código Penal é combater a invasão de dispositivos informáticos, quer estejam ou não ligados à rede de computadores. Dessa forma, para que a conduta delituosa ocorra, o sujeito ativo deve invadir, violando ou transgredindo o dispositivo alheio, sem necessitar

estar conectado à internet, e com o objetivo de conseguir alterar ou destruir dados ou informações.

Ademais, o §1º do artigo 154-A dispõe que incorre na mesma pena quem "produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida" (BRASIL, 2012b, documento *on-line*). Assim sendo, para que se enquadre neste tipo penal, o sujeito ativo deve congregar elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

O §2º do artigo 154-A, que traz uma possibilidade de aumento de pena nos casos em que a invasão resulta em prejuízo econômico, foi recentemente alterado pela Lei nº 14.155, de 2021, a qual endureceu a pena (BRASIL, 2021).

> Os parágrafos 2º ao 5º do [artigo 154-A] preveem formas qualificadas pelo resultado, as quais, em síntese, serão assim configuradas se a invasão tiver como resultado a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais ou sigilosos ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Contudo, caso haja a divulgação, comercialização ou transmissão a terceiros dos dados obtidos mediante as referidas condutas delitivas, a pena será aumentada de um a dois terços. Nesse mesmo sentido, aumenta-se de um terço ou até a metade se o crime cometido for praticado contra o Presidente da República, governadores e prefeitos, Presidente do STF, o da Câmara dos Deputados e Senado, o da Assembleia Legislativa, o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e Municipal e contra pessoas que possuam "cargos máximos" da administração pública direta e indireta, seja qual for a esfera (ALMEIDA *et al*., 2015, p. 229–230).

É importante destacar que os delitos contra inviolabilidade dos segredos têm guarida constitucional, relativamente à proteção da intimidade e da vida privada da pessoa, conforme a disposição do artigo 5º, inciso X, da Carta Magna (BRASIL, 1988).

Além dessas questões, o artigo 154-B também inovou o Código Penal ao passar a prever a natureza da ação penal, indicando, de maneira genérica, que aos crimes cibernéticos a ação penal é pública condicionada à representação, ou seja, a vítima deve autorizar expressamente a autoridade policial a fazer as investigações e o membro do Ministério Público a realizar o início da persecução criminal. Porém, há uma ressalva neste artigo: quando o delito ocorre contra a administração pública direta ou indireta de qualquer esfera de poder, a ação penal será pública incondicionada, ou seja, dispensa-se a representação da vítima (ALMEIDA *et al*., 2015).

Vale ressaltar que também está prevista a proteção da vítima de determinados crimes contra os deletérios efeitos que, eventualmente, podem vir a ser causados pela divulgação pública do fato. Assim, a representação criminal pode ser oferecida sem formalidades, verbalmente ou por escrito,

bastando a demonstração clara do interesse do ofendido em ver apuradas a autoria e materialidade do fato (PACELLI, 2019).

De acordo com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa "conterá a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas" (BRASIL, 1941a, documento *on-line*). Desse modo a denúncia pode ocorrer de maneiras diferentes no âmbito do crime cibernético: quando o fato está vinculado com a necessidade de representação, a denúncia ou queixa é realizada por meio da vítima; nos casos em que a legislação relativa aos delitos cibernéticos indica outra possibilidade, a denúncia será realizada por meio do Ministério Público.

Cabe ainda observar que o processo penal tem ritos procedimentais diferentes, a depender do *quantum* da pena ou da especificidade do delito. Assim, delitos de menor potencial ofensivo tramitam sob o rito sumaríssimo; nos casos em que o crime tiver sanção máxima de 4 anos de pena privativa de liberdade, o procedimento será o do rito sumário; casos em que a sanção máxima for igual ou superior a 4 anos, o rito é o ordinário; finalmente, alguns delitos têm ritos especiais, como é o caso dos crimes contra a vida, de que é exemplo o homicídio, que tramitam sob o rito do Tribunal do Júri (BRASIL, 1941a).

Tal distinção é importante, uma vez de cada um dos ritos têm fases processuais diferentes e, portanto, cada delito, seja comum ou cibernético, será processado de acordo com o rito que for cabível às suas especificidades. No rito ordinário, feita a denúncia ou queixa, o magistrado pode recebe-la ou rejeitá-la. Recebendo-a, abre prazo para que seja apresentada a resposta à acusação. Após análise da peça processual, o juiz pode absolver sumariamente o acusado ou indicar dia e hora para que ocorra a audiência de instrução e julgamento, a apresentação de alegações finais e, finalmente, a proficiência da sentença do caso penal. No rito sumário, o curso do processo é igual ao do rito ordinário. O rito sumaríssimo, adotado pelos Juizados Especiais Criminais, diferencia-se dos ritos ordinário e sumário pois, depois de oferecida a denúncia ou queixa, o acusado é citado para se apresentar em audiência preliminar. Somente após a audiência preliminar ocorre o juízo de admissibilidade, e em seguida o magistrado procede com o recebimento da denúncia (PACELLI, 2019).

Além dessa inovação legislativa, a Lei nº 12.737/2012 também deu nova redação ao artigo 266 do Código Penal, adicionando à espécie do tipo norma-

tivo o serviço informático, telemático ou de informação de utilidade pública, indicando, na mesma medida, que a interrupção ou perturbação das novas formas de comunicação também são consideradas crimes. Por fim, em seu artigo 298, a Lei nº 12.737/2012 modifica o Código Penal, acrescentando parágrafo único em que realizou a equiparação do cartão de crédito e de débito aos documentos particulares (ALMEIDA *et al.*, 2015).

Muito recentemente, em 27 de maio de 2021, passou a vigorar, a partir da data de publicação, a Lei nº 14.155, que também traz alteração ao texto do Código Penal, adicionando penas mais duras contra crimes cibernéticos. A lei ampliou as penas por crime de furto e estelionato cometidos via dispositivos eletrônicos, criando um agravante para o crime de furto realizado por esses aparelhos, estejam ou não conectados à internet, quer por meio da violação de senhas, mecanismos de segurança ou com o uso de programas invasores (VILELA, 2021). Ademais, passou a prever qualificadoras ao tipo penal, nos casos em que o crime cibernético é praticado contra idoso ou vulnerável ou quando a prática delituosa ocorre pela utilização de servidor mantido fora do território nacional (BRASIL, 2021).

Já o crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, passou a prever a fraude eletrônica, com aumento da rigidez da pena nos casos em que:

> [...] a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo (BRASIL, 1940, documento *on-line*).



Saiba mais

Dentre as fraudes eletrônicas mais praticadas nos dias de hoje, estão as seguintes:

> [...] técnicas de engenharia social e de infecção por códigos maliciosos (*malware*), tais como o *phishing* (mensagens com conteúdo enganoso que estimulam o acesso a páginas maliciosas simuladas que coletam dados pessoais), o *vishing* (criminoso que explora a confiança da vítima, fazendo-a crer que a ligação telefônica é autêntica e segura, a fim de induzi-la a praticar ações por ele demandadas), o *man-in-the--midle* (criminoso que se coloca artificialmente entre duas partes que estão em comunicação e, interceptando seu conteúdo, finge ser uma delas para obter dados úteis ao seu intento) e o *sim swap* (criminoso que compra um chip "em branco", explora os protocolos de autenticação da operadora e, assim, ao clonar o número, obtém acesso às mensagens, senhas e até contas de aplicativos da vítima) (LAI; MOURÃO, 2021, documento *on-line*).

No tema do direito cibernético, cabe ainda destacar o Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965, de 2014, importante instrumento publicado no ordenamento jurídico pátrio com o objetivo de estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet no Brasil. Esse documento legal assegura o sigilo de informações, comunicações, dados e registros armazenados, conforme as disposições dos incisos do seu artigo 7º (BRASIL, 2014).

Mesmo com a publicação do Marco Civil da Internet, resta uma grande lacuna no campo do direito penal, uma vez que a lei não alcançou todas as relações cibernéticas, havendo inclusive diversas propostas implementadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos Crimes Cibernéticos que estão sendo avaliadas. Um dos objetivos é estudar a prática de crimes cibernéticos e os efeitos na economia do Brasil, com o intento de tornar o ambiente da rede brasileira menos vulnerável aos crimes virtuais. Dentre possíveis apontamentos relativos à matéria, estaria a implementação de programas de boa governança em empresas vinculadas com publicidade digital, evitando que sejam publicados anúncios que contenham material ilícito ou instiguem práticas ilegais. Além disso, sugere-se que o Ministério da Justiça obrigue instituições financeiras a notificar fraudes cibernéticas, o iria de encontro à entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira.

Outra discussão relacionada com a atualização legislativa diz respeito à ampliação do Marco Civil da Internet, com a adição de redações específicas à seara criminal, com o objetivo de punir possíveis invasões de computadores. Isso tipificaria a conduta de acesso não permitido a qualquer sistema informatizado ou aparelho eletrônico que cause prejuízo econômico, alteração de dados, instalação de vulnerabilidades, obtenção de conteúdo ou controle remoto na plataforma e aparelho em questão. Além destes, também entrariam delitos vinculados à invasão de aparelhos celulares e redes sociais, com uma sugestão de punição de até dois anos de reclusão.

Outro aspecto que deve receber atenção é a teoria geral das provas no processo penal, uma vez que as provas têm o objetivo de reconstruir os fatos investigados no processo, buscando a maior coincidência possível com a verdade dos fatos. Porém, as provas apresentadas no curso da investigação e também durante a persecução penal devem ser lícitas. Já aquelas provas consideradas ilícitas devem ser desentranhadas do processo, uma vez que violam o artigo 5º, LVI, da Constituição Federal de 1988 (PACELLI, 2019).

Nesse sentido, quando se fala em crime cibernético, os meios de prova admitidos são inúmeros, incluindo: mensagens de correio eletrônico (*e-mails*); *prints*, *logs* e endereço de IP; atas notariais virtuais (instrumento que prova qualquer fato que tenha ocorrido no ambiente virtual); solicitação de mandato

de busca e apreensão de celulares, computadores, *tablets* e outros instrumentos eletrônicos que possam evidenciar a ocorrência do crime cibernético; solicitação de autorização de escuta, monitoramento e quebra de sigilo.

Dessa forma, é indispensável, numa sociedade que avança freneticamente em termos tecnológicos, criar mecanismos de combate e controle de crimes virtuais que sejam mais eficazes. Para isso, diante das ciências jurídicas, com especial atenção à legislação de caráter criminal, deve-se dedicar atenção à criação e/ou aperfeiçoamento legislativo, com vistas a conceder à sociedade um ambiente virtual seguro e amparado legalmente em casos de ilícitos penais.



Saiba mais

Também são importantes os esforços rumo à efetivação da defesa cibernética brasileira por meio das Forças Armadas do país. A criação do Programa de Defesa Cibernética, aliada com estudos da Escola Nacional de Defesa Cibernética, indicam a ampliação da proteção da soberania nacional nessa área. O documento MD31-M-07 traz apontamentos de justificativa à indispensabilidade de interpelações relacionadas com o tema, da mesma forma que indica questões operacionais.

Mesmo que o Brasil tenha iniciado sua preparação para encarar uma das principais guerras no contexto geopolítico, ainda há muito que ser feito para que o país esteja preparado para enfrentar os avanços tecnológicos, em especial o combate aos delitos advindos do espaço virtual (FREIRE; CASTRO, 2020).

Tipos penais mais comuns no direito cibernético

Os avanços tecnológicos e as facilidades oferecidas pela rede mundial de computadores trazem uma série de benefícios à sociedade. Ao mesmo tempo, porém, criam um ambiente fértil para práticas criminosas, uma vez que os dados dos usuários passaram a representar importante ferramenta para a prática de crimes cibernéticos.

De acordo com Rossini (2004, p. 44):

> O conceito de "delito informático" poderia ser talhado como aquela conduta típica, ilícita e culpável, constitutiva de crime ou contravenção, dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, praticada por pessoa física ou jurídica, com o uso da informática, em ambiente de rede ou fora dele, e que ofenda, direta ou indiretamente, a segurança informática, que tem por elementos a integridade, a disponibilidade a confidencialidade. Abarca crimes e contravenções penais, alcançando não somente aquelas condutas praticadas no âmbito da internet, mas toda e qualquer conduta

> em que haja relação com sistemas informáticos, quer de meio, quer de fim, de modo que essa denominação abrangeria, inclusive, delitos em que o computador seria uma mera ferramenta, sem a imprescindível "conexão" à rede mundial de computadores, ou a qualquer outro ambiente telemático. Ou seja, uma fraude em que o computador é usado como instrumento do crime, fora da internet, também seria alcançada pelo que se denominou "delitos informáticos".

Nesse sentido, algumas práticas são bastante comuns no ambiente cibernético. Dentre aquelas previamente tipificadas no ordenamento jurídico pátrio, estão:

- estelionato e furto eletrônicos, denominados fraudes bancárias, conforme previsto no artigo 155, §§3º e 4º, II, e no artigo 171, ambos do Código Penal;
- invasão de dispositivo informático e furto de dados, disposto no artigo 154-A do Código Penal;
- falsificação e supressão de dados, tipificações encontradas nos artigos 297, 298, 299, 313-A e 313-B, todos do Código Penal (BRASIL, 1940);
- armazenamento, produção, troca, publicação de vídeos e imagens contendo pornografia infantil, conforme artigos 241 e 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
- assédio e aliciamento de crianças, tipo penal posto no artigo 241-D do ECA (BRASIL, 1990a).

Os crimes contra a honra também são bastante comuns no ambiente cibernético, como calúnia, difamação e injúria, dispostos no Código Penal, entre os artigos 138 e 145. Tais crimes se tornaram práticas frequentes sobretudo nas redes sociais, em que é fácil encontrar a difusão de falsas notícias, além da propagação de mensagens de ódio relacionadas à orientação sexual, raça, etnia, religião, etc.

Ademais, cabe destacar a violação de direitos autorais, prática é bastante corriqueira, especialmente pelo volume de informações dispostos na rede mundial de computadores. Quando uma cópia é realizada com a indicação de citação da autoria, não é considerada ilícita; porém, não é incomum a prática de plágio. Salienta-se que a matéria dos direitos autorais tem guarida na Lei nº 9.610, de 1998 (BRASIL, 1998).

Delitos também comuns no ambiente virtual são os vinculados à privacidade. O conceito de privacidade tem respaldo constitucional no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, que afirma: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" (BRASIL, 1988, documento *on-line*). Porém, com a expansão do acesso à informação e à rede mundial de computadores, não é difícil perceber a crescente invasão da privacidade, uma vez que as formas de acesso aos dados pessoais estão em crescimento exponencial. Tal prática delituosa ganhou proteção quando, no ano de 2012, foi promulgada a Lei nº 12.737 sobre crimes cibernéticos, objetivando aplicar punições mais severas e específicas para quem comete atos criminais na rede mundial de computadores, especialmente aqueles em que o usuário tem sua intimidade atingida por ter seu computador invadido (BRASIL, 2012b).

Ademais, digno de atenção nesse âmbito é o crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. Nesse delito, o agente usa de mecanismos para conseguir obter "vantagem ilícita, prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil, ou qualquer outro meio fraudulento" (BRASIL, 1940, documento *on-line*). De forma análoga, a fraude no ambiente virtual, hoje prevista expressamente pela Lei nº 14.155, de 2021, ocorre quando o patrimônio do sujeito passivo é alcançado através de meio enganoso, ocorrendo a consumação quando o sujeito ativo consegue a vantagem ilícita em prejuízo alheio, sendo corriqueiro em crimes de natureza econômica, ocasião em que o agente criminoso obtém o benefício ilegal via, por exemplo, movimentações bancárias.

Além dessas práticas, os crimes cibernéticos também alcançam as práticas classificadas como hediondas segundo a legislação brasileira. Tais práticas estão definidas no artigo 1º da Lei nº 8.072, de 1990, que prevê que para crimes hediondos não cabem anistia, graça, indulto ou fiança, como é o caso de tortura e terrorismo (BRASIL, 1990b).

Para além dos delitos mencionados comuns na seara cibernética, ainda vale destacar os seguintes crimes:

- ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal;
- *cyberbullying*, prática que vem se difundindo de maneira desenfreada com a ampliação do acesso às redes sociais, muitas vezes envolvendo a criação e publicação de perfis falsos, relacionados com ofensas, que têm guarda nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal;
- interrupção de serviço, prevista no artigo 266, §1º, do Código Penal;
- incitação e apologia ao crime, artigos 286 e 287 do Código Penal;
- crimes de ódio, previstos no artigo 20 da Lei nº 7.716, de 1989;
- venda ilegal de medicamentos, conforme previsão do artigo 273 do Código Penal (BRASIL, 1940).

Um tema corriqueiro entre os operadores do direito é o pedido de reforma do Código Penal, para a inclusão de um capítulo exclusivo para o tratamento de crimes cibernéticos e de informática. Aguarda designação do relator, desde 18 de fevereiro de 2021, o Projeto de Lei nº 236, de 2012, no Senado Federal. Uma vez promulgado, passaria a contemplar, de maneira exclusiva entre os artigos 208 e 211, os crimes cibernéticos (BRASIL, 2012c).

O artigo 208 do referido Projeto de Lei indica a diferenciação entre sistema informático, dados informáticos, provedor de serviços e dados de tráfego. Por sua vez, o artigo 209 passa a tipificar o acesso indevido, com previsão de pena de 1 a 2 anos, que pode aumentar para 4 caso o crime resulte em prejuízo econômico. Já o artigo 210 tipifica a sabotagem informática, enquanto o artigo 211 fala sobre a representação da vítima nos crimes de natureza cibernética, conteúdos que, da mesma forma, estão contemplados no atual Código Penal, a partir das atualizações conferidas por meio da Lei de Crimes Cibernéticos (BRASIL, 2012b).

Em 2013, foi proposto pelo Deputado João Arruda (PMDB/PR) o Projeto de Lei nº 5.555, que trata da disseminação não consensual de imagens íntimas segundo a prática de *revenge porn*, ou pornografia como vingança. Tal projeto objetiva alterar a Lei nº 11.340, de 2006 (Lei Maria da Penha). Tal projeto deu origem à Lei nº 13.772, de 19 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018a).

Ademais, há o Projeto de Lei nº 6.989, de 2017, de autoria do Deputado Odorico Monteiro (PROS), que propõe alterar a legislação para possibilitar a retirada do ar de *sites*, vídeos e outros meios que fomentem indivíduos a atentarem contra a própria vida. Tal projeto se encontra arquivado pela Câmara dos Deputados.

Outro Projeto de Lei nessa área é o nº 9.722, de 2018, de autoria do Deputado Sandro Alex (PSD/PR), que pretende obrigar a criação de mecanismos de identificação em anúncios publicitários na internet, responsabilizando quem administra, intermedia, gerencia, disponibiliza e/ou distribui conteúdo que abarque ilícitos penais. Tal projeto foi apensando ao Projeto de Lei nº 1.070, de 1995, para apreciação do Plenário da Câmara (BRASIL, 2018b).

Cabe destaque, na seara penal, o Projeto de Lei nº 154 de 2019, de autoria do Deputado José Nelto (PODE/GO), que propõe a alteração do Código Penal para o estabelecimento de um agravante genérico para os crimes cibernéticos. Tal proposição também se encontra pronta para apreciação pelo Plenário da Câmara (BRASIL, 2019).

Ainda que diversos Projetos de Lei estejam tramitando junto ao Poder Legislativo, inegavelmente os crimes cibernéticos se tornaram uma realidade no cotidiano da sociedade. A cada dia um serviço novo surge no âmbito digital e, com isso, os delitos cibernéticos tornam-se mais constantes e mais sofisticados. Por tal razão, estudiosos do direito e profissionais que atuam diretamente nessa área clamam pela institucionalização de texto legal relativo à matéria de crimes cibernéticos no Código Penal, naquilo que concerne à edição de um capítulo exclusivo aos delitos de natureza digital e informática dentro da normativa legal penal de 1940.



Exemplo

Um estudo publicado no ano de 2020 (SILVA, L.; SILVA, P.; VILANOVA, 2020) teve o objetivo de analisar como o *cyberbullying* tem contribuído para a violação dos direitos fundamentais por jovens no Brasil. A partir de uma prática extensionista, voltada à conscientização e prevenção do *cyberbullying*, os autores chegaram à conclusão de que a família e a escola desempenham papel social e fundamental para coibir a prática delituosa por adolescentes. Como medida de avanço social, a educação é alternativa essencial para a mudança de paradigmas no processo de transformação da sociedade.

Referências

ALMEIDA, J. de J. *et al*. Crimes cibernéticos. *Cadernos de Graduação*: Ciências Humanas e Sociais, v. 2, n. 3, p. 215–236, mar. 2015.

BITTENCOURT, C. R. *Tratado de direito penal*: parte geral. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940*. Código Penal. Brasília: Presidência da República, 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro 1941*. Código de Processo Penal. Brasília: Presidência da República, 1941a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 3.914, de 09 de dezembro de 1941*. Lei de introdução do Código Penal (Decreto-lei nº 2.848, de 7-12-940) e da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei nº 3.688, de 3 outubro de 1941). Brasília: Presidência da República, 1941b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3914.htm. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990*. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências. Brasília: Presidência da República, 1990a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990*. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências. Brasília: Presidência da República, 1990b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Lei nº 12.735, de 30 de novembro de 2012*. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 — Código Penal, o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, e a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para tipificar condutas realizadas mediante uso de sistema eletrônico, digital ou similares, que sejam praticadas contra sistemas informatizados e similares; e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2012a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12735.htm. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012*. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 — Código Penal; e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2012b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014*. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília: Presidência da República, 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Lei nº 13.772, de 19 de dezembro de 2018*. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar e para criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. Brasília: Presidência da República, 2018a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13772.htm. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Lei nº 14.155, de 27 de maio de 2021*. Brasília: Presidência da República, 2021. Disponível em: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tornar mais graves os crimes de violação de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet; e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para definir a competência em modalidades de estelionato. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Projeto de Lei nº 154/2019*. Brasília: Câmara dos Deputados, 2019. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190632. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Projeto de Lei nº 236, do Senado Federal de 2012*. Brasília: Senado Federal, 2012c. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404. Acesso em: 5 jul. 2021.

BRASIL. *Projeto de Lei nº 9.744/2018*. Brasília: Câmara dos Deputados, 2018b. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2169062. Acesso em: 5 jul. 2021.

CARNEIRO, A. G. Crimes virtuais: elementos para uma reflexão sobre o problema na tipificação. *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, XV, n.99, abr. 2012. Disponível em: http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11529&revista_caderno=17. Acesso em: 5 jul. 2021.

FREIRE, T. M.; CASTRO, R. M. A defesa nacional brasileira e as novas formas de guerra: desafios da soberania cibernética. *In*: SIMPÓSIO DE DEFESA E CIÊNCIA POLÍTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 2., 2020. *Anais...* Recife: UFPE, 2020. Disponível em: https://redectidc.com.br/assets/files/anais-ii-simposio.pdf#page=32. Acesso em: 5 jul. 2021.

LAI, S.; MOURÃO, P. B. *Lei 14.155/2021 dos crimes cibernéticos*. [*S. l.*]: Jusbrasil, 2021. Disponível em: https://sauveilai.jusbrasil.com.br/artigos/1226118167/lei-14155-2021-dos-crimes-ciberneticos. Acesso em: 5 jul. 2021.

LEBRE, M. *Direito penal*: OAB. 2. ed. Curitiba: Aprovare, 2015. (Coleção Caricaturas do Direito).

PACELLI, E. *Curso de processo penal*. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

ROSSINI, A. E. de S. *Informática, telemática e direito penal*. São Paulo: Memória Jurídica, 2004.

SANTOS, J. C. *Direito penal*: parte geral. 6. ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 2014.

SANTOS, L. R.; MARTINS, L. B.; TYBUCSH, F. B. A. Os crimes cibernéticos e o direito a segurança jurídica: uma análise da legislação vigente no cenário brasileiro contemporâneo. *In*: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORANEIDADE: MÍDIAS E DIREITOS DA SOCIEDADE EM REDE, 4., 2017. *Anais...* Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2017. Disponível em: http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2017/7-7.pdf. Acesso em: 5 jul. 2021.

SCHMIDT, G. *Crimes cibernéticos*. [*S. l.*]: Jusbrasil, 2014. Disponível em: http://gschmidtadv.jusbrasil.com.br/artigos/149726370/crimes-ciberneticos. Acesso em: 5 jul. 2021.

SILVA, L. A. C.; SILVA, P. T.; VILANOVA, A. B. B. O Direito e as redes sociais: o advento do cyberbullying e a violaçnao dos direitos fundamentais pelos adolescentes. *Revista Interdisciplinar de Extensão*, v. 4, n. 7, p. 40–54, 2020. Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/conecte-se/article/download/23308/16664. Acesso em: 5 jul. 2021.

VILELA, P. R. *Lei com penas mais duras contra crimes cibernéticos é sancionada*: legislação fica mais rigorosa para furtos e estelionato na internet. Brasília: Agência Brasil, 2021. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-05/lei-com-penas-mais-duras-contra-crimes-ciberneticos-e-sancionada. Acesso em: 5 jul. 2021.

Leituras recomendadas

BRASIL. *Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989*. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Brasília: Presidência da República, 1989. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm. Acesso em: 5 jul. 2021.

LIMA FILHO, P. R. A. O direito penal na quarta revolução industrial: A expansão razoável frente aos crimes cibernéticos. *Delictae:* Revista de Estudos Interdisciplinares Sobre o Delito, v. 6, n. 10, p. 215–304, 2021. Disponível em: https://www.delictae.com.br/index.php/revista/article/view/150/115. Acesso em: 5 jul. 2021.

PADOVEZ, R. S.; PRADO, F. R. O direito penal brasileiro no contexto dos crimes cibernéticos. *In*: ETIC — ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2019. *Anais do ETIC 2019*, v. 15, n. 15, 2019. Disponível em: http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/7962. Acesso em: 25 jun. 2021.

PEREIRA, A. C.; GOMES, J. C. C. Crimes cibernéticos e impactos das novas tecnologias na advocacia criminal. *Anais UniCathedral*, v. 1, n. 2, p. 79–87, 2021.

RODRIGUES, F. J. S.; CARDOSO, S. de A. M.; MARWELL, T. E. D. G. Use of virtual infiltration in police operations to combat sexual crimes against children and adolescents. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 4, e24710414152, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i4.14152. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/14152. Acesso em: 5 jul. 2021.

SOUZA, L. A. Q.; CERVINSKI, Y. É possível a prevenção e combate aos temidos crimes virtuais? *Anuário*: Pesquisa e Extensão Unoesc São Miguel do Oeste, v. 6, e27776, 2021. Disponível em: https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/apeusmo/article/view/27776. Acesso em: 5 jul. 2021.

SOUZA, L. de F. Marco Civil da Internet e crimes virtuais. *Conteúdo Jurídico*, 2018. Disponível em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/51965/marco-civil-da-internet-e-os-crimes-virtuais. Acesso em: 5 jul. 2021.

Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.



PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.



CONTRIBUA COM A QUALIDADE DO SEU CURSO

Se você encontrar algum problema neste material, entre em contato pelo email **eadproducao@unilasalle.edu.br**. Descreva o que você encontrou e indique a página.

Lembre-se: a boa educação se faz com a contribuição de todos!

UNIVERSIDADE
LaSalle
Viver é evoluir.

Av. Victor Barreto, 2288 | Canoas - RS
CEP: 92010-000 | 0800 541 8500
eadproducao@unilasalle.edu.br